

al árbitro. Ejemplo típico es el de las lesiones personales que entran en la categoría del *membrum ruptum*, a propósito de las cuales en las XII Tablas se dispone: *si membrum rupsit ni cum eo pacit, talio esto*. La ley del talión (ojo por ojo, diente por diente) representa ya un progreso frente a la ilimitación de la venganza primitiva; pero un nuevo y más importante progreso es señalado por la cláusula *ni cum eo pacit*, que reconoce oficialmente la facultad de la composición convencional. Más interesante todavía es comprobar que en los textos relativos a la aplicación de la citada norma, la composición está considerada como el resultado normal y que la *actio iniuriarum aestimatoria* del Edicto pretorio no conserva más vestigio de una sanción distinta de la pecuniaria. Legalizado el sistema de la composición, y reducida contemporáneamente la antigua *obligatio*-prenda al deber jurídico de observar el comportamiento voluntariamente asumido frente a otra persona, la posición del delincuente vino a coincidir con la de quien había contraído una deuda: a la *obligatio ex contractu* se yuxtapuso la *obligatio ex delicto*. Que la subsunción de las obligaciones derivadas de contrato y de delito bajo el nombre común de *obligatio*, sea el resultado de un esfuerzo de pensamiento de la jurisprudencia evolucionada se desprende, a falta de otra razón, de la posición que las obligaciones emergentes de delito ocupan en el sistema gayano: de ellas se habla, en efecto, solamente en el apéndice, después que la obligación ha sido estudiada en sus fuentes, en sus efectos, en sus modos de extinción, con exclusiva referencia a las obligaciones contractuales.

*
* *
*

Todo lo que hemos dicho no da todavía la razón de un fenómeno singular que fué primeramente descrito y admirablemente ilustrado por PEROZZI: el de que en la serie de las obligaciones nacidas de convención y de hecho ilícito, que se presentan a nuestro espíritu como respondiendo a principios comunes, hubiera algunas a las cuales los clásicos dieron el nombre de *obligationes*, y otras a las cuales este nombre ha sido aplicado sólo en la compilación justiniana, por efecto de interpolaciones. Así, de los numerosos actos ilícitos descritos en nuestras fuentes, solamente cuatro (hur-

to, robo, *iniuria*, *damnum iniuria datum*) producían en el derecho clásico *obligatio*, mientras ésta no surgía, por ejemplo, en el caso de las acciones *de effusis et deiectis* y *de positis et suspensis*; así, mientras surgía *obligatio* del mutuo, del depósito y del comodato nacía, en cambio, solamente una *actioe teneri*, a la cual los juristas no solían dar el nombre de *obligatio*³.

La causa de este fenómeno está en la contraposición entre las normas del derecho civil y las reglas que proceden de la actividad del pretor. Éste no podría, sin traspasar los límites trazados a su discrecionalidad, crear derechos y obligaciones; y así como no puede crear un *dominium* que se contraponga al *d. ex iure Quiritium* sino solamente garantizar a algunos no propietarios el goce efectivo de la cosa (*in bonis habere*, cfr. ps. 207 y ss.), como no puede atribuir a nadie la *hereditas* sino sólo poner y mantener a cierta clase de sucesores en posesión de los bienes hereditarios (*bonorum possessio*, cfr. cap. xxv, § 1), tampoco puede crear *obligationes*, sino solamente organizar medios judiciales en virtud de los cuales personas que no están civilmente obligadas sean compelidas a pagar una suma como sanción de un daño. Quien está obligado con la acción *de effusis et deiectis* (es decir, el propietario o inquilino de la casa desde la que se arrojó alguna cosa, perjudicando a los transeúntes o a sus cosas) no es *obligatus*, porque la pena pecuniaria le es impuesta no por el derecho civil sino por el Edicto; el depositario, el comodatario, el acreedor prendario no son *obligati*, porque depósito, comodato y prenda no son contratos reconocidos por el *ius civile*, sino causas de responsabilidad sancionadas por primera vez por el pretor.

³ En las primeras ediciones había escrito: "el uso de la palabra *obligatio* es escrupulosamente evitado por los juristas". La corrección se inspira en el criterio metódico que he señalado en la *Storia del dir. rom.*, 5ª ed., ps. 161, n. 1, y 346, n. 1, y que consiste en distinguir entre el modo de analizar (y eventualmente criticar) los textos relativos a las reglas de derecho en vigor y lo que debe prevalecer si se quiere hacer la historia del pensamiento jurídico. El docto estudio de SEGRÈ cit. en la p. 315, que verdaderamente honra a nuestra ciencia, cuenta con mi acuerdo en numerosos aspectos, pero no en la importancia a atribuir a los varios datos; lo que SEGRÈ reconoce (en las ps. 599 y ss. y en otros lugares) es, desde el punto de vista de la historia de las doctrinas, casi toda mi tesis, y a mí me basta, por cierto, con que la contraposición entre *obligatio* y (*honoraria*) *actioe teneri* sea considerada tan fundada (digase también, si se cree, tan infundada) como la existente entre *dominium* e *in bonis habere*.

La prueba más concluyente de esta pertenencia del concepto de *obligatio* al *ius civile* la tenemos en el pasaje de GAYO (IV, 2) en que está definida la *actio in personam* como la que compete contra aquel "qui nobis vel ex contractu vel ex delicto obligatus est, id est cum intendimus DARE FACERE PRAESTARE OPORTERE". No se podría decir con mayor energía que una *obligatio* se tiene solamente cuando en la fórmula de la acción respectiva, exista la afirmación solemne de un deber jurídico (cfr. en la p. 146 la definición de la fórmula *in ius conceptae*). Pero fórmulas que contengan el *oportere* no puede concederlas el pretor sino para dar protección judicial a pretensiones ya reconocidas por el derecho civil; cuando una nueva acción es introducida en virtud del poder discrecional a él mismo atribuido, el magistrado no puede redactar la fórmula *in ius*, no puede hablar de *oportere*, sino que debe limitarse a una redacción *in factum*, en la cual, después de la indicación de lo que, según el dicho del actor, ha pasado entre las partes (por ejemplo, el daño causado por la caída de un vaso, o la falta de restitución de una cosa depositada), ordena al juez que condene, si aquellos presupuestos de hecho subsisten, o que absuelva en caso contrario (GAYO, IV, 45 y 46). Y donde está excluido el *oportere* está excluida la *obligatio*.

Si no me engaño, una preciosa referencia en el mismo sentido está en aquella definición de la *obligatio* de la que hemos partido. Vimos que allí la obligación es descrita como un "iuris vinculum quo necessitate adstringimur... secundum nostrae civitatis iura". En las últimas palabras no se suele poner atención, como si contuvieran solamente la trivial observación de que la obligación debe ser reconocida por el ordenamiento jurídico: tanto más trivial cuanto que ya la expresión "iuris vinculum" habría debido eliminar toda duda al respecto. Aquellas palabras adquieren, en cambio, un significado importantísimo, si la expresión *nostrae civitatis iura* se interpreta como equivalente a *ius civile*; el autor de la definición famosa habría indicado en ella la exclusión de los deberes pretorios de la categoría de la *obligatio*.

En verdad, los compiladores justinianeos no entendieron la frase en este sentido, cuando la reprodujeron en las Instituciones. En el derecho justiniano, en efecto, así como fué en principio abolida la distinción entre derecho civil y pretorio, fueron tam-

bién reunidas bajo un más amplio concepto de *obligatio* las propias y verdaderas obligaciones civilísticas del derecho clásico y los deberes provistos de acción pretoria; ahora nace *obligatio* del *effusum et deiectionum* como del daño, del depósito como de la compraventa.

FRANJA
MORADA

FRANJA MORADA

CAPÍTULO XIII

LAS FUENTES DE LAS OBLIGACIONES

Las clasificaciones de las fuentes en la jurisprudencia clásica en general, en las obras gayanas y pseudogayanas y en la compilación justiniana.

Llamamos fuentes de las obligaciones a los hechos jurídicos que son presupuestos de su nacimiento. En general, son hechos de la voluntad humana; pero los hay ilícitos y lícitos. Característica del acto ilícito (cfr. p. 23) es que la obligación surge contra la voluntad del agente, y como sanción de la inobservancia de una norma lógicamente anterior (el ladrón no roba con el fin de soportar la pena del hurto, sino que la obligación deriva de no haber cumplido con el precepto fundamental de no robar). Entre los actos lícitos se pueden distinguir, en cambio, dos categorías. La primera, que es la más numerosa, comprende las declaraciones de voluntad bilaterales emitidas con el fin de que una de las partes o ambas se obliguen a observar cierta conducta (ejemplos: mutuo, estipulación, compraventa). En la segunda categoría entran los actos lícitos no bilaterales, o no cumplidos con el fin de crear una obligación, y otras situaciones de las cuales el ordenamiento jurídico hace derivar una obligación: así el legado *per damnationem*, el pago de lo indebido, la gestión de negocios, la tutela.

La clasificación predilecta de los juristas romanos parece limitarse a distinguir las dos grandes clases de los actos lícitos e ilícitos: estos últimos toman el nombre de *maleficia* o *delicta*; los primeros el de *contractus*¹. Nombre que en sentido propio se adap-

¹ Sobre esto y sobre cuanto sigue, cfr., además de los estudios ya citados de PEROZZI y mío, también BONFANTE, *Scr. giur.*, 3, ps. 107 y ss., 135 y ss.; BERTI, *Sul significato di "contrahere" in Gaio* (1913), y en el "Bull. Ist. Dir. Rom.", 28, 1915, ps. 3 y ss.; ALBERTARIO, *Studi di dir. rom.*, 3, ps. 71 y ss., 95 y ss.; DE FRANCISCI, *Συνάλλαγμα*, II, 1916, ps. 317 y ss.;

ta, según el pensamiento latente de los mismos juristas², sólo al negocio jurídico bilateral dirigido a crear un vínculo obligatorio; pero que la jurisprudencia extiende, con visible esfuerzo, también a casos en los cuales el negocio bilateral falta, buscando en ellos cualquier cosa que pueda asemejarse a la resultante de dos declaraciones de voluntad. Cuando se afirma, por ejemplo, a propósito del legado *per damnationem*, que el heredero obligado a pagarlo *non sponte cum legatarius contrahit* (D. 50, 17, 19, pr.), está claro que se hace un esfuerzo para encontrar algo parecido a una declaración de voluntad cambiada entre el heredero y el legatario (y la búsqueda es vana porque la fuente de la obligación no está en la conducta del heredero sino en la declaración del testador); análogamente, a propósito de la acción correspondiente a quien ha costeado los gastos de un funeral, se dice (D. 11, 7, 1 pr.) que "qui propter funus aliquid impendit cum defuncto contrahere creditur non cum herede", palabras que no sabría interpretar sino como ficción de negocio jurídico. No es distinto el valor de los textos en que se afirma la naturaleza contractual del pago de lo indebido.

De la clasificación gayana de los contratos y de la descripción que sigue de las diversas categorías y de los tipos particulares (III, 89-162) resulta también que la jurisprudencia ha partido precisamente de la idea del contrato como acto o declaración bilateral; no sólo no se encuentra allí indicado ninguno de los actos lícitos productores de obligación que no se traduzcan en declaraciones bilaterales, sino que quien quisiere completar el sistema introduciendo en los *genera contractuum* las figuras omitidas por GAYO, no podría incluir convenientemente en él ni el legado ni la gestión de negocios ni la tutela. Y no se puede pensar que actúe

RICCONONO, *Dal dir. rom. class., etc.*, ps. 263 y ss., 689 y ss., y *La formazione della teoria generale del "contractus"*, en *Studi Bonfante*, 1, ps. 123 y ss.; GROSSO, *Il sistema romano dei contratti* (curso univ.), Torino, 1945; VOCI, *La dottrina rom. del contratto*, Milano, 1946.

² Digo "pensamiento latente" porque en tanto que no habrían de otra manera podido reducir a unidad las diversas acepciones de la palabra, ellos atribuyen, sin embargo, en el mutuo, mayor valor a la dación de la cosa que a las declaraciones del mutuante y del mutuario, y en los contratos formales los *verba* y las *litterae* absorben y a veces exceden la voluntad.

De ahí la gran dificultad del tema; en el estudio del cual, mientras se han señalado oportunamente las divergencias entre los diversos juristas, se ha descuidado con frecuencia el grave elemento perturbador procedente de no haber sido elaborado por los antiguos el concepto del negocio jurídico (cfr. p. 26).

aquí una especial tendencia sistemática de GAYO: también esta parte de los contratos, como todo su manual, lleva los signos de la reelaboración de una obra anterior, que en las primeras fases se refiere a los juristas del fin de la República. Lo que es propio de GAYO, aquí como en otras partes, es el acomodarse a resultados que la jurisprudencia de su tiempo tendía a superar, con la fe absoluta de quien ha formado sobre pocos libros, y fuera de las grandes corrientes de pensamiento, su educación científica.

En nuestro caso, la fidelidad de GAYO a los *veteres* ha hecho que él, más realista que el rey, se ofuscara con el único ejemplo que el modelo le ofrecía, de contrato no reductible a la declaración de quererse obligar: el pago de lo indebido. En efecto, después de haber transcrito (III, 91) las palabras con las cuales su autor destacaba la analogía de defensa judicial y de estructura jurídica entre mutuo y pago de lo indebido, prosigue: "*sed haec species obligationis non videtur ex contractu consistere, quia is, qui solvendi animo dat, magis distrahere vult negotium quam contrahere*".

En los pseudogayanos *libri rerum cottidianarum*³, aprovechados para esta parte —en dos redacciones diferentes— en las Instituciones justinianas (3, 13, 2; 3, 27; 4, 5) y en el Digesto (44, 7, 1 a 5), el breve asomo crítico ya citado se transforma en la base de toda una nueva clasificación de las fuentes de obligación. Mientras en las Instituciones GAYO había mantenido firme (III, 88) la clasificación *in duas species*, "*omnis enim obligatio vel ex contractu nascitur vel delicto*", salvo al ponerse en contradicción con ella en el citado § 91, en el texto del Digesto las obligaciones "*aut ex contractu nascuntur aut ex maleficio aut proprio quodam iure ex variis causarum figuris*"; de estas varias especies de causas, pues, algunas estarían tan lejanas del contrato como del delito; otras, en cambio, serían afines al delito, por lo que los deudores "*videntur quasi ex maleficio teneri*". En las Instituciones imperiales, las *causae* que en el Digesto quedaban aisladas son reconocidas, a su vez, como afines al contrato, y la tripartición de las fuentes de las obligaciones se transforma en cuatripartición: la obligación nace, ahora, *ex contractu aut quasi ex contractu, ex maleficio aut quasi ex maleficio*; y aquellas *variae causarum figurae*, que en el

³ Sobre su composición, y en particular sobre los fragmentos relativos a las fuentes de las obligaciones, cfr. mi estudio citado en la p. 11, n. 7.

Digesto están todas reunidas en la citada ley 5, se separan en dos direcciones, para ir a constituir una el título "de obligationibus quasi ex contractu" (3, 27), la otra el título "de obligationibus quae quasi ex delicto nascuntur" (4, 5).

La claridad de la cuatripartición es considerada desde hace mucho tiempo sospechosa, también a causa del contraste en que se halla con la tripartición del Digesto. Mucho mayor fe ha alcanzado, frente a ella, esta tripartición, severamente criticada, sin embargo, por PEROZZI desde el comienzo del siglo. Pero lo cierto es que mientras el sistema de las Instituciones lleva en la clasificación cierta coherencia, aquellas *variae causarum figurae* del Digesto, que en parte se aproximan al delito y en parte permanecen suspendidas en una especie de limbo, no se pueden considerar más que como un primer e informe bosquejo de una clasificación ajustada a las exigencias de la plenitud y de la facilidad de formulación, particularmente sentidas ambas en la doctrina posclásica. Una y otra partición son productos de escuela; y yo pienso que procedían simplemente de dos diversas versiones llamadas, quizá, una *Res cottidianae* y *Aurea* la otra, de una misma paráfrasis de las Instituciones gajanas, compilada en varias ediciones por profesores de las escuelas posclásicas⁴.

Científicamente, la cuatripartición (que por haber sido recogida en las Instituciones puede considerarse como la doctrina oficial de los justinianeos) tuvo el solo mérito de refirmar de una vez para siempre el concepto del contrato como acuerdo de voluntades productivo de obligación. En cuanto al resto, decir que en ciertos casos la obligación nace como de contrato, equivale a no decir nada sobre la estructura de los actos de los cuales nace efectivamente la obligación; y cuando, con una fácil trasposición de la terminología de los compiladores, los romanistas construyeron la categoría del *cuasi contrato*, reunieron bajo esta denominación actos y hechos que sólo tienen de común el carácter negativo de no ser contratos en el sentido expresado. Alguno, como el legado *per damnationem*, es un negocio jurídico que tiene por fin crear una obligación, con la salvedad de que ésta recaerá sobre una persona extraña al negocio; algún otro, como el pago de lo inde-

⁴ En mi estudio citado había hablado de la "escuela de Berito o de Constantinopla"; prefiere pensar en una escuela occidental SCHULZ, *History of Roman legal science*, Oxford, 1946, p. 167.

bido, es también un negocio jurídico, pero destinado en la intención de las partes a un fin muy distinto que el de crear una obligación; y la gestión de negocios no es siquiera un negocio jurídico, sino una mera aplicación de la actividad individual en un campo que le está señalado por la intención de hacer cosa útil a otro.

De todos modos, los cuasi contratos están unidos en un mismo grupo por la falta del acto bilateral destinado a hacer nacer una obligación, pero entre el delito y el cuasi delito no hay siquiera una diferencia de estructura jurídica, por mucho que la hayan fatigosamente buscado los romanistas y después los civilistas, dado que durante mucho tiempo los códigos modernos han continuado hablando de delitos y de cuasi delitos (así en Italia también el de 1865, pero no el Código de 1942, que titula a la respectiva sección, "de los hechos ilícitos"). Sobre todo no es exacto ni aun para el derecho justiniano, por más que muchas veces se lo haya repetido y aun cuando pueda reconocerse una tendencia de los compiladores en este sentido, que el delito sea acto doloso (intencional) y el cuasi delito culposo (es decir, derivado de negligencia); el *damnum iniuria datum*, que también está comprendido entre los delitos, se funda sobre la culpa del autor del daño.

Los casos que las fuentes justinianas enumeran como cuasi delitos tienen de común solamente el origen histórico, es decir, el derivar no del derecho civil sino del pretorio. Por esta razón habían quedado fuera no sólo del esquema clásico de los delitos sino de todo el sistema de las *obligationes* propiamente dichas; considerándolas como fuentes de obligaciones *quasi ex delicto*, los compiladores de las *Res cottidianae* consiguieron un doble fin: fundir en una sola, también para esta parte de los actos ilícitos, las causas civiles de obligación y los hechos de los que derivan acciones pretorias; y dar satisfacción, con la correspondencia del cuasi delito al cuasi contrato, a su amor por las bellas construcciones uniformes.

FRANJA MORADA

CAPÍTULO XIV

LAS OBLIGACIONES NACIDAS DE CONTRATO

§ 1. EL CONTRATO Y LA ACCIÓN CONTRACTUAL

En el capítulo precedente nos hemos referido ya a la concepción del contrato en el derecho romano clásico y en el justiniano. Corresponde recordar que según la terminología dominante en la jurisprudencia clásica, se llaman *contratos* aquellos negocios jurídicos bilaterales del *ius civile* (en antítesis al pretorio), destinados a producir obligaciones: sea que en el pensamiento de los antiguos prevalezca la idea del acuerdo de voluntades o consentimiento (lo que ocurre solamente en los contratos *consensu*), sea que la intención de obligarse o de obligar a otro frente a sí se trasfunda íntegramente en el uso de determinadas formas (contratos *verbis* y *litteris*) o en la entrega de ciertas cosas corporales (contratos *re*). Por lo demás, el no haber distinguido de los contratos otra categoría de hechos lícitos productores de obligación, imponía a los juristas incluir entre los primeros, mediante el empleo de la ficción jurídica, fuentes de obligación que no eran negocios bilaterales.

En el derecho justiniano, la categoría de los contratos, al mismo tiempo que se extiende por la inclusión de las relaciones análogas que estaban tuteladas sólo por el derecho pretorio, rechaza, por el contrario, todas las fuentes de obligación que no sean reducibles a un acuerdo de voluntades (*conventio*, *consensus*). Este acuerdo, que para los clásicos era casi siempre relegado a segundo plano por el elemento real o formal, es ahora un requisito esencial de todos los contratos, ya sea que el consentimiento baste, de cualquier manera que sea expresado, para producir el vínculo (contratos *consensu*), o que deba ser revestido de cierta

forma (contratos *verbis* y *litteris*) o acompañado por la entrega de cosas (contratos *re*).

Al consentimiento, que representa así —en la concepción justiniana— el elemento subjetivo de todo contrato, se contrapone, como elemento objetivo, la *causa*. Hemos señalado ya (p. 90) que por causa de un negocio jurídico se entiende la fundamental intención de las partes; en materia de contratos, y según la opinión que consideramos más correcta, se puede llamar causa a esa conducta o compromiso de la contraparte sobre cuya base cada una de las partes se adhiere al contrato. Así, la causa de la compraventa está, para el comprador, en la obligación del vendedor de transmitirle el goce de la cosa, y para el vendedor en la obligación del comprador de pagarle el precio; la causa del mutuo está, para el mutuante, en la obligación que el mutuario contrae frente a él; para el mutuario, en la transferencia que el mutuante le hace del dinero o de las mercaderías. Sin embargo, debe recordarse que, como en general los negocios jurídicos, también los contratos pueden ser *causales* o *formales*, y que solamente a los primeros es esencial la existencia de causa; en los contratos formales domina la palabra pronunciada o escrita, y la falta de la causa puede dar lugar solamente a una excepción, mediante la cual el deudor demandado puede no ya negar la obligación, sino contraponerle una razón por la cual sea inicuo pretender su ejecución (cfr. ps. 148 y ss.).

Desde otros puntos de vista se suelen distinguir:

1º) Contratos *a título gratuito* y *a título oneroso*, según que obtenga ventajas uno solo de los contratantes (ya sea el acreedor o el deudor) o que ambos saquen provecho de él. Es a título gratuito el depósito que se hace en provecho exclusivo del depositante (acreedor), como así también el comodato, hecho exclusivamente en beneficio del comodatario (deudor); son a título oneroso la compraventa y la locación.

2º) Contratos *unilaterales* y *bilaterales*, según que nazca obligación para una sola de las partes (como del mutuo) o para ambas (como de la compraventa). Intermedios entre las dos categorías son los llamados contratos bilaterales imperfectos, que se tienen cuando, aun quedando normalmente obligada una sola de las partes, nace, sin embargo, en ciertas eventualidades, también una obligación para la otra; así, en virtud del depósito, está normal-

mente obligado sólo el depositario, pero puede surgir también alguna obligación para el depositante, de resarcir —por ejemplo— los gastos realizados por aquél para la conservación de la cosa o de los daños que ella le haya ocasionado.

3º) Contratos *iuris civilis* y *iuris gentium*, según que sean practicables sólo entre romanos o también entre romanos y extranjeros y entre extranjeros (cfr. p. 29). Al segundo grupo, que nació, como sabemos, de las relaciones comerciales entre Roma y los otros países del Mediterráneo, y se afirmó a través de la jurisdicción del *praetor peregrinus*, pertenecen en particular los cuatro contratos consensuales de compraventa, locación-conducción, sociedad, mandato.

En el uso clásico de la expresión, no se tiene *contractus* que no sea civil en el significado con que esta palabra se opone a *pretorio*. La acción contractual es, por esto mismo, *in ius concepta*, fundada sobre un *oportere* (p. 146). En los casos en que la primera protección judicial ha sido dada por el pretor mediante fórmulas *in factum conceptae* (como para el depósito, el comodato, la prenda), la idea del contrato ha sido precedida por la de la ilicitud en retener la cosa de otro, y por esto las respectivas acciones *in factum* conservan algún vestigio de un régimen que las aproximaba a las acciones derivadas de delito. Pero son exclusivamente vestigios; y el régimen clásico de dichas relaciones está inspirado en su analogía con los contratos propiamente dichos, encontrándose dado a veces el nombre de *contractus* también al depósito.

Mayor relieve tuvieron los *bonae fidei iudicia*. Los contratos nacidos del comercio internacional y tutelados por el pretor peregrino no podían dar lugar a un *oportere* puro y simple, expresión que aludía a un deber impuesto por el *ius civile Romanorum*, pero sí a obligaciones fundadas sobre aquella recíproca confianza que era necesaria entre comerciantes acostumbrados a encontrarse en los mercados de cada país. Estas obligaciones, que sólo como consecuencia de un largo desarrollo se hicieron objeto de análisis y de clasificación, estaban primero designadas con la expresión estereotípica "*quidquid ob eam rem (venta, locación, etc.) dare facere oportet ex fide bona*" (véase un ejemplo en la p. 140), y como tales, remitidas por el pretor peregrino al examen de un colegio arbitral en el cual estaban quizá representadas las diversas nacionalidades. Mantenido en las fórmulas procesales de los ne-

gocios inspirados en el *ius gentium*, reproducido también en fórmulas nuevas que con el *ius gentium* no tenían ya nada que hacer, el *oportere ex fide bona* conservó una particular ductilidad, una aptitud para ajustarse a los más sutiles matices de la voluntad de las partes y a las más diversas exigencias de la conciencia jurídica, que hicieron de él un factor de primer orden en la evolución del sistema contractual. El régimen particular de los *bonae fidei iudicia* deberá ser destacado muchas veces en el resto de la exposición; pero aquí corresponde insistir sobre dos puntos. Uno, que mientras por regla general toda exigencia equitativa opuesta a la acción del acreedor debe ser explícitamente invocada por el deudor ante el magistrado e introducida en la fórmula como *exceptio*, sin lo cual el juez no podría tomarla en cuenta (ps. 148 y ss.), las excepciones fundamentales —o por lo menos la *exceptio doli*— se consideran inherentes a los *bonae fidei iudicia*, de manera que el demandado puede siempre hacer valer ante el juez sus defensas¹. Otro, que las fórmulas de los juicios de buena fe son tales que consienten que se tengan en cuenta no sólo las pretensiones del actor contra el demandado, sino también las del demandado contra el actor, por lo menos dentro de los límites en que éstas pueden ser sustraídas de aquéllas, es decir, hasta la absolución del demandado. En cambio, es controvertido si para algunos juicios de buena fe, especialmente para los de mandato y de gestión, se haya llegado a admitir que a instancia del demandado la fórmula pudiese atribuir al juez el poder de pronunciar la condena, según los resultados de la causa, a cargo indiferentemente de una o de otra parte². De todos modos, la amplitud y finura de los poderes que de ella resultaban para el juez era ya profundamente sentida en la época ciceroniana. En antítesis con los *b. f. iudicia*, las acciones de otra manera correspondientes para tutela de los contratos son, a veces, designadas con los nombres de *actiones stricti iuris* o *stricti iudicii* o *iudicia stricta*, denominaciones que parecen propias del lenguaje posclásico.

Característica de las acciones que nacen del contrato es su correspondencia no sólo al acreedor y contra el deudor, sino a los

¹ Véase sobre el tema las vastas investigaciones de GROSSO (espec. en *Studi Urbinati*, 1-2, 1927-1928).

² La fórmula diría, por ej.: *Quod As As No No mandavit ut hominem venderet, qua de re agitur, quidquid ob eam rem alterum alteri dare facere oportet ex fide bona*, etc.

herederos de uno y contra los herederos del otro. Si esta transmisibilidad *activa* y *pasiva*, indudable no sólo en la época clásica sino también en los últimos siglos de la República, fué originaria, o si, como sería conforme con aquel carácter de autopignoración que hemos visto ser propio de la obligación primitiva, hubiera sido precedida por un período en el cual deudas y créditos se extinguían con la muerte de una de las partes (o por lo menos con la del deudor), es problema al que no se puede dar respuesta segura³.

Como residuo histórico de una primitiva intrasmisibilidad de las obligaciones nacidas de contrato, se suele considerar la máxima por la cual *obligatio ab heredis persona incipere non potest*. Ella importa que el vínculo obligatorio, aun el sujeto a condición o término, debe ser tal que pueda disolverse en vida de las partes. En consecuencia, no es ineficaz, por ejemplo, la estipulación de dar dentro de veinte, treinta o cincuenta años, ni se hace ineficaz por el hecho de que antes del término muera el obligado; pero es ineficaz la estipulación sujeta al término *post mortem tuam* o *post mortem meam*, como también las estipulaciones *heredem meum dare*, o *heredi meo dari*. La razón de la máxima es tan poco sentida en la época clásica que se encontró el

³ La intrasmisibilidad originaria fué sostenida con energía por KOORMAN, *Fragmenta iuris Quiritium*, Amsterdam, 1914, ps. 160 y ss.; y más recientemente por KOROSZEC, *Die Erbenhaftung nach römischen Recht [La responsabilidad de los herederos según el derecho romano]*, Leipzig, 1927; contra este último escrito véase, sin embargo, BONFANTE, "Arch. Giuridico", 100, 1928, ps. 3 y ss.; y RABEL, "Rev. Fundac. Savigny", 49, 1929, ps. 580 y ss. Los argumentos invocados en apoyo de la antigua intrasmisibilidad no tienen todos igual valor; pero hay algunos que impresionan. Así, cuando se piensa que las obligaciones de garantía contraídas por los *sponsores* y *fidepromissores* eran también en la época clásica intrasmisibles a los herederos, y máxime si se acepta la tesis según la cual la *sponsio* en garantía de la deuda ajena era originariamente la única estipulación que tenía eficacia jurídica, la intrasmisibilidad originaria de las obligaciones contractuales se hace probable. Ni me parece que se haya verdaderamente refutado el argumento de analogía que se saca de la extinción de la obligación en caso de sucesión universal *inter vivos* (*adrogatio* o *conventio in manum*). De cualquier manera, corresponde señalar que la eventual evolución de la intrasmisibilidad a la transmisibilidad se ha cumplido en época antiquísima, y que las obligaciones contractuales eran ya consideradas transmisibles por las XII Tabas; los esfuerzos de KOROSZEC para quitar valor a los testimonios respectivos y atribuir el nuevo principio al derecho pretorio son indudablemente vanos.

modo de eludirla con la estipulación *cum moriar* o *cum morieris*, a cuyo respecto —lo atestigua GAYO, III, 100— se consideraba que el término venciese no ya después de la muerte, sino en el último momento de la vida.

El contrato no puede, en general, tener efectos sino entre las partes contratantes. De ahí derivan las prohibiciones de las promesas en favor de terceros y de las promesas relativas al hecho de un tercero⁴.

La regla *alteri stipulari nemo potest* importa, ante todo, que no pueda nacer acción para el tercero del crédito que queremos hacerle adquirir; se discute si puede nacer acción para el estipulante, en cuanto tenga un interés propio en que el deudor observe el comportamiento que se le impone en relación con aquel tercero. El medio más ampliamente usado por los romanos para hacer exigibles semejantes promesas fué el de la estipulación penal: yo me hago prometer una suma de dinero para el caso de que no se realice cierta prestación en favor de Ticio; es claro que, en este caso, de la falta de prestación al tercero nacerá en mi favor la acción por la penal. El derecho justiniano admite también, en casos excepcionales, que nazca una acción para el tercero; así para el inquilino, cuando el locador, al vender la casa a otro, se haya hecho prometer que el inquilino sería mantenido en el goce de la casa; para el propietario de una cosa entregada en comodato o depósito, cuando el comodante o depositante no propietario haya pactado que la cosa le sea restituída a aquél; para el constituyente de la prenda, cuando el acreedor haya vendido la cosa prendada estableciendo en su favor un derecho de rescate; en fin, para el descendiente *in potestate* en cuyo favor el ascendiente haya estipulado la restitución de la dote.

En cuanto a la promesa del hecho de un tercero, parece que deba distinguirse entre las varias épocas y quizá también entre los diversos fines a los cuales puede tender la promesa. Las antiguas promesas de garantía (*praedictura*, *sponsio*, etc.) eran, según parece, promesas del hecho de un tercero; sólo en época posterior el garante se obligó al pago juntamente con el garantido, y en este punto su obligación se pudo construir como promesa del he-

⁴ Cfr., en particular, PACCHIONI, *I contratti a favore dei terzi*, 3ª ed., Torino, 1933; RABEL, *Lineamenti*, ps. 505 y ss. El tema no debe confundirse con el de la representación, sobre el cual cfr. ps. 105 y ss.

cho propio. Pero quedan todavía en la época clásica ciertas asunciones de garantía, en las que parece prometerse una conducta negativa de todos los asociados (así las promesas de garantía por evicción; cfr. § 4, n° 1): aquí debía ser decisiva para los clásicos, la función de la promesa, no obstante que tuviese formalmente por objeto el hecho ajeno. Sólo JUSTINIANO, según parece, excluye de modo absoluto la eficacia de toda promesa del hecho de un tercero, salvo el acostumbrado remedio de la cláusula penal.

§ 2. LOS CONTRATOS REALES Y LOS CONTRATOS INNOMINADOS

Diversa extensión de la categoría en el derecho clásico, en el justiniano y en la especulación científica posterior. Los contratos reales nominados en particular: 1) mutuo; 2) fiducia; 3) depósito; 4) comodato; 5) prenda. — 6) Los contratos innominados.

Entre los casos en que la obligación nace de contrato, GAYO distingue (III, 89) según que la obligación se contraiga *re* o *verbis*, o *litteris* o *consensu*; con lo que quiere decir que el vínculo obligatorio nace del desplazamiento de una cosa (que pasa del poder del acreedor al del deudor), o del hecho de que ciertas palabras solemnes sean pronunciadas (*verba*) o escritas (*litterae*), o del de que las partes se hayan puesto de acuerdo. La dogmática moderna prefiere apoyar la distinción sobre la base del concepto unitario de contrato, y clasifica precisamente los contratos en reales, verbales, literales y consensuales.

De las cuatro categorías antedichas, la que en el sistema de las Instituciones gayanas es la más restringida, es también la que el derecho posclásico, con conocimiento de causa o sin él, ha extendido más ampliamente. Para GAYO (III, 90 y ss.) *re contrahitur* aquella *obligatio* que nace de la *trasmisión de la propiedad* de una cosa o de una cantidad de cosas de una persona a otra, a la cual incumbe la obligación de restituirla o de restituir otro tanto; pero mientras no existan más que dos negocios bilaterales que correspondan a este concepto (mutuo y fiducia), GAYO se ocupa solamente del primero, y de éste pasa a tratar, del modo que hemos visto (p. 327), de la *indebiti solutio*. El porqué de esta omisión no es fácil de discernir; pero la causa más probable es que en el pensamiento de los juristas, acercándose la fiducia a

una *mancipatio*, se veía en ella más bien un *pactum* que un *contrato* propiamente dicho⁵.

En cambio, en los célebres pasajes que el Digesto y las Instituciones reproducen de las diversas versiones de las *Res cottidianae*, y en los cuales la fusión entre obligaciones civiles y deberes pretorios se halla plenamente realizada (ps. 327 y ss.), la categoría de los contratos *re* recibe el refuerzo de otros tres: depósito, comodato, prenda. En ninguno de ellos concurre el presupuesto del clásico *re contrahere* (al acreedor prendario no pasa la propiedad sino la posesión, y depositario y comodatario no son siquiera poseedores sino detentores); pero ellos tienen de común con el mutuo que la obligación surge solamente cuando la cosa ha pasado de manos del acreedor a las del deudor, y que sobre éste pesa la obligación de la restitución; en este sentido, bien puede decirse que aquellos contratos son reales. Los justinianeos no han visto, en cambio, que la estructura de los contratos innominados, por ellos mismos definitivamente acogidos en el sistema y regulados, debía conducir a extender todavía la categoría en cuestión; no porque todos los contratos innominados presupongan la entrega de una cosa (esto sucede en los tipos *do ut des* y *do ut facias*, no ya en los tipos *facio ut des* y *facio ut facias*), sino porque, ya se trate de la entrega de una cosa o de cualquier otro comportamiento, la obligación surge solamente cuando uno de los contratantes haya ya observado la conducta que es causa de la obligación del otro; por ejemplo, uno de los permutantes está obligado a transferir al otro la propiedad de una de las dos cosas, en cuanto el otro le ha transmitido ya la que funciona como equivalente; uno de los contratantes está obligado a manumitir su esclavo, en cuanto el otro le ha transmitido ya, a este fin, la propiedad de otro esclavo. Si en la compilación justiniana no se pone de relieve esta identidad de estructura, se trata de un defecto sistemático de la compilación misma; y en tal defecto repararon los comentadores, los que siempre han aproximado los contratos innominados a los reales.

*
* *
*

⁵ Voci (Scritti Ferrini, 1946, p. 392, nº 3; *Dottr. del contr.*, ps. 121 y s.) aplaude la omisión, y yo confieso que tengo a propósito siempre más dudas; pero no me parecen decisivos los argumentos invocados.

1. El *mutuo* (o préstamo de consumo) es un contrato por el cual una de las partes (mutuante) trasfiere a la otra (mutuario) la propiedad de cierta cantidad de dinero o de otras cosas fungibles, bajo la promesa no solemne de restitución de una cantidad igual de cosas del mismo género y calidad (*tantumdem*)⁶. Momento de perfección del contrato es el del paso de la propiedad de las cosas del mutuante al mutuario; un acuerdo que obligase al acreedor a dar en mutuo no tendría según el derecho romano ningún valor si fuese concluido sin formas solemnes, y si se lo concluyese en la forma de la *stipulatio* (ver más adelante § 3) sólo daría lugar a la obligación de resarcir los daños derivados al interesado de la circunstancia de que no se le hiciese el préstamo (cfr. D. 45, 1, 68). Del mutuo nace sólo la obligación del mutuario; en consecuencia, es el más típico contrato unilateral⁷.

Por lo general, las cosas objeto del mutuo deben pertenecer al mutuante, y pasar en el momento del contrato a propiedad del mutuario. Se admitieron, sin embargo, no sin resistencia (cfr. especialmente D. 17, 1, 34 pr.), equivalentes, por ejemplo, que Ticio reciba de Cayo una cosa con el encargo de venderla y de retener el precio a título de mutuo (D. 12, 1, 11 pr.), o que alguien retenga a título de préstamo la suma recibida de otro precedente deudor de su acreedor y por delegación de éste (ley 15, D. *h. t.*). Mucho más lejos fué el derecho justiniano, llegando en ciertos casos a admitir un mutuo hecho sin conocimiento del mutuante, como en la interpolada ley 9, § 8, D. *h. t.*

La restitución del *tantumdem* debe hacerse al término; si no hay término fijado, el acreedor puede pretenderla en cualquier momento, pero por derecho justiniano el juez está facultado para concederle una equitativa dilación.

En tutela de su crédito no corresponde al mutuante una acción especial, fundada sobre el mutuo como tal, sino aquella acción

⁶ Cfr. GAYO, III, 90, quien da también la falsa etimología de *mutuum = quod ex meo tuum fit*. La verdadera etimología es, en cambio, de *mov* - (*movere, mutare*).

⁷ El caso de que las cosas dadas en mutuo dañen al mutuario, contemplado por ejemplo en el art. 1821 del Cód. Civ. italiano, pero verdaderamente poco probable dado el género de las cosas que son objeto de mutuo, no es tomado en consideración por el derecho romano como un caso de responsabilidad contractual. El Código de 1865 señalaba entre las "obligaciones del mutuante" las que son los límites de su derecho y de la obligación del mutuario; artículos justamente suprimidos en el Código de 1942.

formal (cfr. p. 142, n. 17) que se llama *condictio*, y que nace del incumplimiento de cualquier deber jurídico de dar, reconocido por el derecho civil. Tiene dos formas y dos nombres, según que sea dinero (*actio certae creditae pecuniae*) el objeto de la obligación (en nuestro caso del mutuo), u otra cosa (*condictio certae rei* o *condictio triticaria*); en la primera hipótesis el demandado es condenado a la misma suma que debía pagar y no pagó (v. la fórmula en la p. 140); en la *condictio certae rei*, en cambio, no se llega a la condena pecuniaria sino a través de la estimación de las mercaderías debidas, salvo que en el curso del juicio el deudor no entregue las mercaderías mismas; de donde, en la fórmula, el acostumbrado *QUANTI EA RES ERIT, TANTAE PECUNIAE IUDEX... CONDEMNATO*, etc.

De la estructura de las fórmulas, especialmente de la de la *a. certae creditae pecuniae*, deriva una consecuencia aparentemente extraña; la esencial gratuidad del mutuo romano. La cual no debe entenderse en el sentido de que el derecho romano haya prohibido en todo tiempo el préstamo a interés (antes bien, si en algún período hubo prohibición, su duración fué muy breve, y la legislación se orientó solamente en el sentido de limitar en diversa medida la tasa)⁸, sino solamente en el sentido totalmente formalista y procesal, de que con la *condictio* no se puede pretender una suma mayor que la correspondiente a la dación de la que ha surgido la

⁸ Una disposición limitativa se tiene ya en las XII Tabas; y contempla probablemente aquellas relaciones de deuda que encontraban la garantía en el *nerum* (cfr. *supra*, p. 317). El límite máximo del interés es la *uncia* (de donde el nombre de *fenus unciarium*), es decir, 1/12 del capital; pero se discute si la tasa en cuestión debe entenderse como mensual o como anual. En favor de la primera opinión se pronuncia APPLETON (en el trabajo citado en la p. 186, n. 5), mostrando cómo la tasa del 100 % al año debiese parecer a los antiguos mucho menos odiosa que a nosotros, dada la extrema rareza del medio circulante, la escasa garantía que los deudores podían ofrecer, y la ya notable proporcionalidad del interés a la productividad de las semillas y de los animales de trabajo que eran objeto de los préstamos primitivos.

Posteriormente se dictaron varias otras disposiciones, de las cuales la tradición nos da noticias no siempre resistentes a la crítica (cfr. últimamente la exposición de KOOIMAN, op. cit., ps. 303 y ss.). Entre las famosas leyes Licinias Sextias del año 367 a. C., una de carácter transitorio habría ordenado el cómputo de los intereses ya pagados en el capital; pero ya pocos años después, en el año 357, una *lex Duilia Menenia* habría reconfirmado, contra la inobservancia de los ciudadanos, el límite del *fenus unciarium*; en el año 347, un plebiscito de *fenore semiunciario* habría reducido el interés a la mitad (50 % al año); en fin, en el año 342 una *lex*

obligación. Para alcanzar el resultado económico del préstamo a interés, es necesario que la dación en mutuo vaya acompañada por una especial estipulación de *usurae*; en este caso, el mutuante podrá intentar, contemporáneamente, contra el deudor que no cumple, dos acciones: una por la *sors* (= capital) prestada, otra por las *usurae* estipuladas. Pero esto debió influir también sobre la aplicación práctica de nuestro contrato; probablemente el mutuo ha quedado como fuente exclusiva de la obligación solamente en los casos en que el préstamo era realmente gratuito; toda vez que el acuerdo relativo a los intereses hacía necesaria la estipulación especial, se prometía, en la forma de la estipulación, también el capital⁹.

Genucia lo habría directamente prohibido. De la exactitud de esta última noticia se duda bastante, sobre todo porque la tradición misma refiere también para el tiempo posterior providencias siempre renovadas contra la usura, sin vincularlas nunca a la pretendida prohibición absoluta; de una *lex Porcia fenebris*, propuesta por Catón el mayor, se habla para el año 118, de una *lex Marcia* para el año 104, de una *lex Cornelia Pompeia unciaria* (donde la *uncia*, si de ella se trataba, era entendida no ya por mes sino por año) para el año 88 a. C. La usura, que en la época de crisis de los ordenamientos republicanos fué practicada también por los hombres más representativos a tasas impresionantes, debió realizarse mediante fraudes, desgraciadamente fáciles en todo tiempo y lugar. En la edad imperial, la tasa normal del interés es del 12% al año (*usurae centesimae*, según el cálculo por mes). En el imperio cristiano se tiende a límites más restringidos; y Justiniano reduce la tasa normal al 6%, y también a menos en hipótesis particulares. Prohibido está también, y en el derecho justiniano más rígidamente que en el clásico, el *anatocismo*, es decir, la cláusula contractual que considera a los intereses no pagados como un capital productivo, a su vez, de intereses; y está también prohibido el ulterior curso de los intereses cuando, en cualquier modo y tiempo, su suma haya doblado el capital.

⁹ Son muy instructivas, a propósito, las tablillas de Transilvania, documentos de la aplicación práctica del derecho romano en el siglo II d. C. Véase, por ejemplo, el documento del año 162 en C. I. L. III, p. 934 (*Negotia*, n° 122), donde se recuerdan conjuntamente el mutuo, la *stipulatio* de la suma mutuada, la *stipulatio usurarum*: "Denarios sexaginta qua die petierit probos recte dari fide rogavit Iulius Alexander, dari fide promisit Alexander Caricci (*stipulatio sortis*); et se eos denarios sexaginta, qui supra scripti sunt, mutuos numeratus accepisse et debere se dixit (*causa stipulationis* = *mutuum*), et eorum usuras ex hac die in dies triginta centesimas singulas dari... fide rogavit Iulius Alexander, dari fide promisit Alexander Caricci (*stipulatio usurarum*)". Sobre el problema de la relación entre las dos *causae debendi*, que en el derecho clásico se reducen a la sola estipulación, mientras que en el justiniano se suman en un contrato complejo, *re et verbis*, cfr. Segrè, *Mutuo e stipulatio nel diritto romano classico e giustiniano*, en los *Studi in onore di V. Simoncelli*, Napoli, 1917, ps. 331 y ss.

Hay algunas reglas que, establecidas para el mutuo, se aplican a todo contrato que tenga su estructura económica, aunque esté revestido de la forma de la estipulación o del contrato literal. Tal la prohibición de prestar dinero a los hijos de familia, preparada —parece— por rescriptos del emperador Claudio, y sancionada en el senadoconsulto Macedoniano en la época de Vespasiano (69-79 d. C.). El senadoconsulto no impedía que surgiese la obligación para el hijo de familia, pero invitaba al pretor a denegar la acción al acreedor, o a conceder, si el caso era dudoso, una *exceptio*. Pero si el deudor hubiera pagado, no podía repetir la suma (de allí la pretendida inclusión de nuestro caso entre las obligaciones naturales; cfr. cap. XIX, § 1). La excepción del senadoconsulto cesa si el padre ha consentido el contrato antes, contemporáneamente o después de su perfeccionamiento, o si el deudor, que se ha hecho *sui iuris*, ha ratificado la deuda.

Suele afirmarse que el principio de la esencial gratuidad del mutuo sufre dos excepciones: una para el llamado *fenus nauticum*, otra si el mutuante es un ente público. Mejor es decir que en ambos casos se está fuera del campo de aplicación del mutuo, aun tratándose de negocios económicamente análogos.

El *fenus nauticum* (o *pecunia traiectica*) es una institución muy difundida en el mundo griego, e importada de Grecia a Roma a fines de la época republicana. Consiste en un préstamo de dinero destinado al comercio marítimo, con asunción del riesgo de la navegación por parte del acreedor, quien recuperará la suma solamente si la nave cumple felizmente su viaje. El alto riesgo tiene como recompensa, por un lado, la prestación de intereses elevados (por el derecho justiniano, el límite se fija en el doble del normal); por el otro, un especial derecho de prenda sobre las mercaderías adquiridas con la suma anticipada; es más: una exacta investigación sobre los casos particulares descritos por los oradores áticos (y por Demóstenes especialmente), parece probar que la propiedad de esas mercaderías es del acreedor, hasta que el armador no la haya rescatado restituyendo el capital y los intereses¹⁰. Esta institución, acogida en Roma por razones prácticas, quedó en ella como un cuerpo extraño, más bien tolerado por la jurisprudencia que sometido al rigor de su disciplina; en las obras sistemáticas de

¹⁰ Cfr. a propósito PRINGSHEIM, *Kauf mit fremdem Geld* [Compra con dinero ajeno], Leipzig, 1916.

comentario al derecho civil o al Edicto no encontró lugar, y no se sabe bien en qué forma se desarrolló su tutela judicial¹¹.

En cuanto al mutuo de las *civitates*, contemplado como productivo de intereses en D. 22, 1, 30, cabe observar que el hecho de que en la relación jurídica sea parte un ente público y el de la relación directa con los fines de administración pública, da a menudo también a los contratos de las *civitates* una estructura diversa de aquella de las relaciones análogas entre particulares (cfr. p. 79); como la enfiteusis y la superficie (cap. x), también la dación en préstamo debe haber sido considerada más bien desde el punto de vista de la concesión administrativa que desde el del contrato, y la defensa judicial de las partes debe haberse desarrollado fuera del sistema formulario, según las reglas de la *cognitio extra ordinem*.

*
* *

2. Se ha hecho referencia varias veces a la *fiducia*, sea como aplicación de la *mancipatio* (ps. 90 y 223), sea en cuanto precede a la prenda y a la hipoteca como modo de garantía de las obligaciones (ps. 291 y ss.); pero también debe tomársela en consideración como contrato, y precisamente como un contrato en virtud del cual alguien, a quien para un fin determinado le ha sido transmitida por otro una cosa mediante *mancipatio* o *in iure cessio*, se obliga a remanciparla o a volver a cederla *in iure* cuando dicho fin se haya cumplido. Desde el punto de vista del fin a que tiende la transmisión, se distingue una *fiducia cum creditore* y una *fiducia cum amico*: se tiene la primera cuando la propiedad es transmitida en garantía de un crédito; la segunda sirvió, en cambio, para realizar varios otros fines que en el antiguo ordenamiento no podían lograrse con medios más idóneos. Es probable, por ejemplo, que en el tiempo que precedió al reconocimiento pretorio del depósito, la entrega en confianza de las propias cosas a una persona para que las conservase y las restituyese a requerimiento del que las entregó se hiciese mediante *fiducia*; igualmente, antes de que el pretor reconociese el comodato, la *fiducia* quizá haya tenido fun-

¹¹ Véase, por último, los dos estudios de DE MARTINO en "Riv. del Dir. della Navigaz.", 1, 1935, ps. 217 y ss., y 2, 1936, ps. 433 y ss.; y BRICARDI, en *Studi senesi*, 1947.

ción de préstamo de uso. A ella debe haberse recurrido también en los períodos más turbios de la historia de Roma, para salvar los propios bienes de las proscripciones o del pillaje, confiándolos a personas cuya posición social o política ofreciese mayores garantías de inmunidad¹². En fin, sirvió para realizar las donaciones modales (p. 104) o *mortis causa* (cap. xxvii).

Originariamente, la convención que acompañaba el traspaso de la propiedad no tuvo existencia autónoma; la *fiducia cum creditore*, que es el tipo más antiguo, debió parecerse a toda otra *mancipatio*, es decir, solemnizar el cambio entre la *res Mancipi* y su precio, mientras que el compromiso del comprador de remancipar la cosa cuando la otra parte estuviese dispuesta a restituírle su precio, debió quedar confiado a su corrección. Pero más tarde, cuando en el formulario de la *mancipatio* y de la *in iure cessio* se introdujo el inciso *fiducia* (o *fidei fiduciae*) *causa* o se lo acompañó con un pacto circunstanciado sobre los derechos y las obligaciones del adquirente, los juristas separaron este *pactum* del acto de transmisión del dominio con el cual estaba vinculado; y en época poco anterior a Cicerón, le dieron una protección judicial. Surgió así la *actio fiduciae*, en cuya fórmula, después de la mención de la operada transmisión de la cosa, y de los relativos acuerdos entre las partes, se invitaba al juez a verificar si el demandado se había comportado, en la conservación y restitución de la cosa, *uti inter bonos bene agere oportet et sine fraudatione*; la amplitud de los poderes así atribuídos al juez, y la analogía entre la frase citada y el *oportet ex fide bona*, hicieron que la fórmula en cuestión fuese incluida entre los *bonae fidei iudicia*, y que hasta fuese considerada casi como su prototipo¹³.

¹² Interpreto así el pasaje de BOECIO, *ad Cicer. Top.*, 10: "...veluti si quis tempus dubium timens amico potentiori fundum Mancipiet, ut, ei, cum tempus quod suspectum est praeterierit, reddat". La expresión *potentior* (sobre la cual cfr. MITTEIS, *Mélanges Girard*, II, ps. 225 y ss.) haría pensar en las relaciones de *patrocinium* que se acostumbró constituir durante la crisis económica del Bajo Imperio (cfr. p. 283); pero es probable que BOECIO haya referido con palabras más en correspondencia con los tiempos sus noticias relativas a la época de las guerras civiles. Duda de mi interpretación SOLAZZI, *Per il XIV centenario della compilazione*, Pavia, 1934, ps. 370 y s.

¹³ Las razones que me llevan a negar (con el lamentado ROTONDI y con DE FRANCISCI) que hubiese ahí una doble fórmula, *in factum e in ius*, las he expuesto en los *Studii econ.-giur.* Cagliari, 4, 1912, 2, ps. 97 y ss. (= *Rariora*, ps. 56 y ss.); de acuerdo, ahora, también LENEL, *Edictum*, 3ª ed.,

En pleno vigor en la época ciceroniana, considerada como vigente por GAYO (II, 59 y ss.), documentada por un precioso tríptico pompeyano del siglo I y por la *tabula Baetica* que es, quizá, del siglo II d. C.¹⁴, la fiducia se halla todavía mencionada en aquellas partes de las *Sententiae* de PAULO que, efectivamente, se remontan hasta principios del siglo III. Pero ya no era más una institución de gran difusión, por haber sido en la mayor parte de sus aplicaciones superada ya por la prenda y por la hipoteca, ya por el depósito y por el comodato. En la época posclásica la fiducia desaparece, y los compiladores justinianos han evitado su nombre en el Digesto, pero a la ciencia moderna le ha sido posible volver a encontrarla en muchos pasajes, en los que su nombre aparecía sustituido por los de los contratos entonces reconocidos¹⁵.

*
* *

3. El depósito es un contrato real, imperfectamente bilateral, consistente en la entrega de una cosa mueble a alguien que se compromete a conservarla y a restituirla a requerimiento del que la entregó. Damos el nombre de depositante al acreedor (*qui depositum*) y de depositario al deudor (*qui depositum suscepit*). La gratuitud es, para los clásicos, elemento esencial; solamente el derecho justiniano expresa mediante interpolaciones (cfr. D. 13, 6, 5 § 2; 47, 8, 2 § 23) la tendencia a considerar que el pago de una módica retribución no desnaturaliza el contrato.

El depósito no es antiquísimo; aunque un texto diga que en el sistema de las *legis actiones* se concedía una acción *in duplum*

p. 293, aunque por razones técnicas formularias (en mi opinión, no decisivas) él tienda a considerar esa única fórmula como *in factum concepta*. Nuevas y complejas conjeturas ofrece KRELLER, "Rev. Fundac. Savigny". 62, 1942, ps. 143 y ss.

¹⁴ Véaselas en mis *Negotia*, n.º. 91 y 92.

¹⁵ Con relación a la prenda, este descubrimiento es el resultado más notable a que haya conducido el llamado método sistemático en la búsqueda de las interpolaciones. En los comentarios de Ulpiano y de Paulo *ad edictum*, a juzgar por las inscripciones de los pasajes trascritos en el Digesto, se hablaría del *pignus* dos veces: por Ulpiano en el libro 28º y en el 30º, por Paulo en el 29º y en el 31º. LENEL pudo establecer que mientras en el primer lugar los dos juristas discurrían verdaderamente sobre la prenda, en la segunda exponían el régimen de la fiducia.

contra el depositario infiel, todo lleva, en cambio, a creer que se tratase de un caso de aplicación de la acción de hurto no flagrante, que correspondería en la hipótesis de que alguien intentase apropiarse de la cosa que se le confió. Una verdadera protección del depósito existió, sin embargo, por obra del pretor, quien prometió una acción contra el depositario que no restituyese la cosa¹⁶, y creó, en consecuencia, una *formula in factum* especial para el caso (verla en la p. 146). Con posterioridad, y más precisamente parece que en los primeros decenios del Imperio, penetrada ya la conciencia jurídica por la exigencia de la tutela de la relación, se agregó a esta fórmula *in factum* otra de buena fe. Ambas fórmulas conservaron su vigor durante toda la época clásica, correspondiendo al actor la elección entre una y otra: según la opinión dominante, la segunda pudo ser intentada, con las oportunas modificaciones, también como *actio contraria*, es decir, por el depositario contra el depositante.

Las obligaciones esenciales del depositario y las eventuales del depositante fueron analizadas por la jurisprudencia sobre la base de las fórmulas recordadas. El depositario está obligado a conservar la cosa, y le está prohibido usarla; si viola esta prohibición, responde, no sólo con la *a. depositi*, sino también con la *a. furti*, como culpable de *furtum usus*. Está, pues, obligado a restituir la cosa con todas sus accesiones, con los frutos recogidos durante el tiempo del depósito, no deteriorada; si alguna de estas condiciones falta, la cosa se tiene por no restituida. En cuanto al depositante, está obligado a resarcir los daños que la cosa haya ocasionado al depositario y los gastos que éste haya realizado; se discute si por derecho clásico estas pretensiones encontraron todas su protección en la *a. depositi contraria*, o si en ciertas hipótesis el depositario estuviese protegido exclusivamente por un derecho de retención ejercible cuando la acción normal fuese intentada por el depositante¹⁷.

¹⁶ La cláusula edictal, reproducida en D. 16, 3, 1 § 1, está probablemente integrada en el sentido indicado por BETTI, *Studii sulla litis aestimatio*, II, 1915, p. 18.

¹⁷ BRONDI, *Iudicia*, ps. 90 y ss., piensa que en el derecho clásico el campo de acción del *iudicium contrarium* (que sería no de buena fe sino *in factum*, no edictal sino decretal) fuese muy restringido, y que en particular para el resarcimiento de los gastos hechos en la cosa el depositario (como también el comodatario y el acreedor prendario) gozase sólo de un derecho de retención. Puede ser que esto sea exacto, y sobre todo la análoga demostración recientemente suministrada para los gastos del

Del depósito se destacan, con régimen en parte diferente, tres figuras particulares:

a) El *depósito necesario* o *miserable*. La cláusula del Edicto distingue del depósito normal el depósito efectuado con ocasión de graves calamidades públicas o privadas (*quod tumultus incendii ruinae naufragii causa depositum sit*); en consideración a la particular perfidia de que en tales hipótesis da prueba el depositario infiel, la acción que en el depósito normal lleva a una condena al simple valor de la cosa, corresponde aquí *in duplum*.

b) El *secuestro*. PAULO (D. 16, 3, 6): "Proprie... in sequestre est depositum, quod a pluribus in solidum certa condicione custodiendum reddendumque traditur". El caso más frecuente es el de la cosa litigiosa consignada a una persona de común confianza para que la custodie hasta la sentencia; pero se tiene secuestro también, por ejemplo, si se deposita en manos de un tercero el importe de una apuesta. Los caracteres jurídicos que distinguen el secuestro del depósito normal se reducen a dos: que mientras el depositario normal es un simple detentor *alieno nomine*, el secuestratario es poseedor *ad interdicta* (cfr. p. 303), y que mientras el depositario está normalmente obligado a restituir la cosa al primer requerimiento, el secuestratario no puede restituirla sino cuando esté decidida la controversia, o cumplida de otra manera la condición. De todos modos, se trata, sin embargo, siempre de un caso de depósito; por eso, en nuestra opinión, hablan con exactitud los textos del Digesto que aplican también al secuestro la *actio depositi*, mientras está probablemente interpolado algún pasaje que configura una especial *a. depositi sequestraria*.

c) Más amplio desarrollo merece el llamado *depósito irregular*. La doctrina y la legislación dan hoy este nombre a un depósito de cosas fungibles, del cual nace para el depositario la obligación de restituir no las mismas cosas individualizadas sino otras tantas del mismo género; por lo común, con las consecuencias ulteriores de que el depositario pueda servirse de las cosas fungibles depo-

poseedor de buena fe frente a la *rei vindictio* (p. 243) proporciona a la tesis de BIONDI gran atractivo; no parece, sin embargo, que él llegue a conciliarla con el pasaje de MONESTRINO en Coll. 10, 2, 5, donde las frases "apud eundem iudicem utiliter experitur" y "exactionem intendit", tienen toda la apariencia de referirse a la correspondencia de una acción especial.

sitadas, y que esté obligado al pago de un interés. Contrato, como se ve, de estructura mucho más próxima al mutuo que al depósito, del cual toma el nombre, en cuanto que, mientras el depósito se perfecciona transmitiendo la mera tenencia de la cosa, aquí se transmite al depositario la propiedad. Y si el nombre del depósito aparece aun en estos casos espontáneamente también en el lenguaje de los negocios, ello ocurre en vista de la situación recíproca de las partes: mientras el mutuo es normalmente concluido a requerimiento del mutuuario, que tiene necesidad de dinero o de mercaderías, en cambio en el depósito irregular el dinero es entregado a personas o entidades (sobre todo Bancos) que tienen amplísima disposición de capitales, de manera que el particular no advierte siquiera que concurre con el propio dinero al buen éxito de vastas especulaciones ajenas, sino que más bien percibe solamente la ventaja que le resulta de la casi absoluta seguridad de la custodia. Y ciertamente, en algunas partes del mundo antiguo se daba el nombre de depósito a contratos del género descrito; basta leer, para persuadirse de ello, el *Trapezitico* de ISÓCRATES¹⁸.

Está demostrado por signos no dudosos que también entre los romanos se tendía, especialmente en el lenguaje de los profanos, a extender en la misma dirección la terminología del depósito. En un caso sometido a examen de PAPINIANO (D. 16, 3, 24), y que nosotros diremos de depósito irregular, el *accipiens* hablaba de *commendare*, y el jurista se adelanta, antes de toda discusión, a reconocer que *commendare* equivale a *deponere*. Otras veces, para hacer inteligibles sus decisiones, los mismos juristas debieron polemizar con el lenguaje común y mostrar cómo se debe distinguir cuidadosamente entre el *deponere* que tiene por fin la restitución de las mismas cosas depositadas y aquel que sólo persigue la restitución del *tantundem*.

Por lo demás, parece que en la época republicana la jurisprudencia no tuviese dificultad en admitir que también éste fuese un caso de depósito, y que el pasaje de ALFENO, en D. 19, 2, 31, aun-

¹⁸ No cito más, como en las primeras ediciones, los papiros greco-egipcios: aquí el llamado depósito (*παρὰκαταθήκη*) de dinero es un mutuo proplamente dicho, al cual, para elevar en alta medida el interés, se aplica mediante una ficción la norma en virtud de la cual el depositario infiel (en un depósito regular) debía restituir el doble. Cfr. mis *Lineamenti del sistema contrattuale nel dir. dei pap.*, Milano, 1928, ps. 59 y ss.

que interpolado en alguna parte, se moviese precisamente en este orden de ideas¹⁹. Pero a la jurisprudencia de los primeros siglos del Imperio, bastante más refinada en el uso de los medios técnicos, pareció que el paso de la propiedad al *accipiens*, la facultad de usar las cosas recibidas, la obligación de restituir el *tantundem*, el pacto relativo a los intereses, fueran obstáculos insuperables para acoger la noción del depósito, y que la dación de una cosa a alguno *ut tantundem redderet* debiese considerarse siempre como mutuo, cualquiera que fuese el fin dominante. Y en este sentido debieron decidir PAPINIANO (leyes 24 cit. y 25, § 1, *h. t.*) y PAULO (leyes 26, § 1, y 29, § 1, *h. t.*). Estos textos fueron interpolados por los justinianeos, pero no tan hábilmente como para que la falsificación no pudiese descubrirse; sobre todo, porque olvidaron corregir otros pasajes en que se afirmaba que el uso de la cosa depositada, consentida por el depositante, transforma el depósito en mutuo, afirmación que no podría conciliarse con la admisión del depósito irregular²⁰. De todos modos, es indudable la existencia de la nueva institución en el derecho justiniano. En definitiva, es un fenómeno bastante menos raro de lo que se podría creer, el hecho de que

¹⁹ Convengo con la opinión hoy dominante en considerar interpolada la frase *idem iuris esse in deposito*, con lo que sigue; pero cuando ALFENO distingue dos especies de *res locatae*, según que el *conductor* (*conductor operis* de la terminología más reciente: cfr. *infra*, p. 385) deba restituir la misma cosa o pueda sustituirla con otra del mismo género, no encuentra un obstáculo en el hecho de que la locación (otro tanto en cuanto al depósito) es normalmente concebida en relación con una cosa determinada en su individualidad. Y precisamente de una ecuación semejante entre la individualidad de la cosa no fungible y el género a que pertenece la fungible, nace el depósito irregular. Que para la segunda entre las hipótesis de locación por él contempladas, ALFENO piense en dar la *condictio certae rei* antes que la *a. locati*, es opinión tan absurda como difundida; no sólo ALFENO se habría guardado bien, en tal caso, de hablar de *res locatae*, sino que no es concebible la *condictio* de un anillo o de un vaso contra quien ha recibido de nosotros un lingote de oro o una barra de plata (otros argumentos en el mismo sentido en SOLAZZI, "Riv. del Dir. della Navig.", 2, 1936, ps. 268 y ss.).

²⁰ Cfr. sobre el tema: NABER, *De deposito usurario*, en "Mnemosyne", 34, 1906, ps. 59 y ss.; LONGO, *Appunti sul dep. irreg.*, en "Bull. Ist. di Dir. Rom.", 18, 1906, ps. 121 y ss. No me parece alcanzada la demostración de SEGRÈ (*Sul dep. irreg. in dir. rom.*, en "Bull." cit., 19, 1907, ps. 197 y ss.) de que el depósito irregular fuese admitido por Papiniano, ni fundada la opinión de RABEL (*Lineamenti*, p. 146) en el sentido de que Paulo concediese la acción de depósito por los intereses.

JUSTINIANO viniese a satisfacer por esta vía una aspiración práctica ya sentida *ab antiquo*.

*
* *
*

4. El *comodato* o préstamo de uso es un contrato real, imperfectamente bilateral, consistente en la entrega de una cosa mueble o inmueble a alguien a quien se permite hacer uso de ella por cierto tiempo o con cierto destino, para luego restituirla al acreedor. Se acostumbra dar, a quien entrega la cosa, el nombre de comodante; el de comodatario, a quien la recibe: nombres no romanos sino de los comentadores. También aquí la gratuidad es esencial, subsistiendo como tal en el derecho justiniano; el pago de un precio en dinero por el uso, trasformaría el comodato en locación de cosas, y una compensación de distinta naturaleza lo haría entrar en la categoría de los llamados contratos innominados.

La denominación primitiva de la institución es *utendum dare*, y, por cuanto se puede extraer del texto algo alterado de D. 13, 6, 1 § 1, este nombre se repetía en los edictos anuales de los pretores republicanos; el nombre nuevo de *commodatum* (de *commodo datum*) parecería haber sido oficialmente adoptado por primera vez en la redacción de JULIANO, aunque también precedentemente estuviese en uso para indicar aquel tipo predominante de *utendum datum* que tenía por objeto una cosa mueble.

Mientras del depósito, que no admite el uso de la cosa por parte del depositario, pueden ser indiferentemente objeto cosas consumibles e inconsumibles, del comodato, que se funda sobre el uso, sólo pueden serlo normalmente las cosas inconsumibles; por eso el comodato se suele oponer al mutuo como un préstamo de uso en antítesis con un préstamo de consumo. Pero, puesto que la distinción entre cosas consumibles se funda sobre el uso normal, nada impide un comodato de cosas consumibles cuando se pacte un uso particular; los romanos atribuyen especial relieve al comodato *ad pompam vel ostentationem*; que se da cuando alguien se hace prestar dinero o mercaderías para mostrar momentáneamente que las posee, pero pueden configurarse otras hipótesis, como la de quien se hace prestar mercaderías con fines de estudio o monedas para tomar exacto conocimiento de ellas y evitar que lo sorprendan las falsificaciones.

El comodatario, que es normalmente el único contratante para quien nace obligación, está obligado a no exceder, en el uso de la cosa, los límites de tiempo y de destino que el comodante le ha impuesto, o, a falta de determinación particular, los límites que resulten del uso normal y de aquel que habitualmente hace de la cosa el mismo comodante; de otra manera, responde por el *furtum usus*. Está obligado a la restitución cuando ha transcurrido el tiempo fijado o el suficiente al uso para el cual se le entregó la cosa, incluso si eventualmente no la hubiera usado.

Protegido por primera vez por el pretor, mediante especial cláusula edictal (D. 13, 6, 1 pr.), el comodato fué provisto de una *a. in factum*; posteriormente, un proceso análogo al que se verificó en materia de depósito, condujo a la concesión de una fórmula *ex fide bona*. Pero es cierto que esta última etapa se cumplió muy tarde, quizá por primera vez en el Edicto juliano²¹.

Sobre el comodante pueden recaer las mismas obligaciones que hemos visto para el depositante; se discute si el comodatario, para hacerlas valer, tiene como único medio la retención de la cosa o también una *q. contraria*, y si ésta es *in factum* o *in ius concepta*.

* *

5. De la prenda como derecho real de garantía se ha hablado ya (ps. 291 y ss.). Como contrato real sólo corresponde considerar el *pignus* en sentido estricto (*pignus datum*), que se tiene cuando alguien trasfiere en posesión una cosa corporal, en garantía de una deuda propia o ajena, con la obligación de quien la recibe de conservarla y de restituirla cuando se cumpla la deuda, o de restituirla, si la obligación permanece incumplida, lo que quede del precio en que venda la cosa una vez satisfecho el crédito (*hyperocha*).

También aquí la obligación recae en primer lugar sobre el pignoratario (o acreedor pignoraticio); pero el pignorante puede incurrir, aparte de las responsabilidades que hemos visto para el depositario y el comodatario, también en otras conexas con la

²¹ Cfr. *SEGRE, Sull'età dei giudizi di buona fede di comodato e di pegno*, en los *Studi in onore di C. Fadda*, VI, ps. 333 y ss.; *BRONDI, Iudicia b. f.*, ps. 259 y ss.

función de garantía; así si ha dado en prenda una cosa ajena, o de valor inferior al declarado. Sin embargo, parece que en estas últimas hipótesis correspondiese al acreedor pignoraticio solamente una *a. doli*, y para el resarcimiento de los daños y gastos un derecho de retención. Si era así, acciones derivadas del contrato como tal había una sola en derecho clásico: la *in factum* del pignorante contra el pignoratario. Solamente los compiladores justinianos habrían incluido la acción pignoraticia entre los *bonae fidei iudicia*, e interpolado varios textos para hacer figurar en ellos una *contraria* junto a la *actio directa*²².

* * *

6. Los llamados *contratos innominados*. — Para entender exactamente esta categoría de convenciones, corresponde recordar que el punto de partida en el desarrollo de la doctrina romana del contrato no está en un concepto genérico de *contractus*, capaz de acoger en sí, como un recipiente, cualquier contenido obligatorio, sino en el haber reconocido poco a poco la oportunidad de que surgiese, de ciertos actos o declaraciones de voluntad, la obligación del comportamiento correspondiente; en un segundo momento, todos estos negocios fueron reunidos bajo la denominación de *contractus*. Pero de la agrupación no derivó completamente una sustitución de los tipos particulares, por la nueva categoría, en el sentido de que fuese lícito (como lo es hoy) concluir cualquier negocio obligatorio que responda a ciertos requisitos generales²³. Ni siquiera en el derecho justiniano se reconoció tal libertad contractual; pero en la compilación se afirma el principio de que cuando dos personas se han puesto de acuerdo sobre una prestación

²² Cfr. ARANGIO-RUIZ, *Studii econ.-giur.* cit., ps. 88 y ss. (= *Rariora*, ps. 43 y ss.); y con más vasta investigación BRONDI, op. cit., ps. 233 y ss.

²³ Todo esto en cuanto nos atengamos a la dogmática de los antiguos. Veremos en seguida que uno de los contratos formales, la estipulación, es capaz de cualquier contenido; esto equivale, prácticamente, a decir que todo negocio obligatorio es válido, siempre que se lo concluya en la forma de la estipulación. Pero para los romanos es la forma la que identifica y contradistingue la institución, de manera que la *stipulatio* se halla colocada, en el orden de los negocios jurídicos, en el mismo plano que los negocios formales específicos, como el contrato literal, y que los negocios causales, también ellos específicos, como el mutuo y la compraventa.

y una contraprestación lícitas, y una de las dos ha observado por su parte el comportamiento que había asumido, surge para la otra la obligación de cumplir la contraprestación. Los contratos cuya validez deriva no de la circunstancia de estar particularmente regulados por el derecho objetivo, sino de la subsunción bajo este punto de vista general, son precisamente aquellos que la doctrina bizantina recoge bajo la categoría del contrato innominado (*ἀνώνυμον συνάλλαγμα*) y que ya en el Digesto están contrapuestos a las convenciones que tienen un *proprium nomen*, una *propria appellatio*.

En D. 19, 5, 5 (atribuido a PAULO, pero gravemente interpolado), los contratos innominados se distinguen según la estructura de las prestaciones y contraprestaciones, en cuatro tipos:

do ut des, si la prestación cumplida y la que se espera consisten ambas en la transferencia de la propiedad de una cosa (permuta);

do ut facias, si la prestación cumplida consiste en una transmisión de propiedad y la que debe cumplirse en cualquier otro comportamiento (por ejemplo, te trasmito la propiedad de uno de mis esclavos para que manumitas a otro esclavo tuyo; te doy un anillo para que me pintes un fresco);

facio ut des, en la hipótesis inversa (si, en los ejemplos dados, el primero en cumplir es el amo manumitente o el pintor);

facio ut facias, si ambas prestaciones tienen un objeto distinto de la transmisión de propiedad (ejemplo: dos acreedores se ponen de acuerdo para el recíproco cobro de los créditos en las respectivas plazas, o dos empresarios se obligan a construir, uno para el otro, en diversas localidades, una casa de campo).

Siempre en el supuesto de que uno de los dos contratantes haya cumplido por su parte, el derecho justiniano ofrece toda una serie de medios judiciales:

a) A fin de obtener la repetición de lo que se dió o la indemnización por lo que se hizo a la espera de la contraprestación del otro contratante que no se ha cumplido. En los casos de tipo *do ut des* y *do ut facias*, se puede pedir la restitución de la cosa transmitida intentando la *condictio*, en las dos formas usuales de la *actio certae creditae pecuniae* y de la *condictio certae rei*; en esta aplicación particular, la *condictio* toma el nombre de *c. ob rem dati re non secuta*, o *causa data causa non secuta*. En los casos de tipo *facio ut des* y *facio ut facias*, puesto que *factum infectum fieri*

nequit, se da con fines indemnizatorios la acción subsidiaria destinada a reprimir la conducta maliciosa que otro ha tenido o tiene hacia nosotros, es decir, la *actio doli* (cfr. ps. 116 y ss.).

β) Aun cuando no exista una demora injusta en la contraprestación, pero siempre que ésta no se haya verificado todavía, hay casos en que quien ha transmitido la propiedad de una cosa puede repetirla por desistimiento unilateral de la convención. También aquí corresponde la *condictio*, pero no como c. *causa data causa non secuta*, sino como *condictio ex poenitentia*.

γ) En fin, se puede actuar para obtener la contraprestación. Aquí la acción no puede ser más que una, de alcance general (γενική ἀγωγή la llamaron los bizantinos) y adaptable a circunstancias variadísimas; sin embargo, no hay medio judicial que en las fuentes tenga tantos nombres diversos: *actio incerti*, *civilis incerti*, *in factum civilis*, y más a menudo, *agere* y *actio praescriptis verbis*.

De estos medios y grupos de medios, hay uno —el segundo— que está fuera de cuestión; su pertenencia exclusiva a los justinianeos es, en efecto, opinión común de los romanistas. La *condictio ex poenitentia* se vincula, efectivamente, a toda una doctrina bizantina del desistimiento unilateral, a la cual como veremos se refiere también el nuevo régimen de las *arrhae* (p. 374).

Pero también es singular la concurrencia entre los medios del grupo α y los del grupo γ. El comprador que ha pagado el precio y no ha recibido la cosa puede pretender la entrega de esta misma, no ya la restitución del precio; ¿por qué el permutante ha de gozar de la ventaja de la elección entre la restitución de la cosa que ha dado y la entrega de la que se le debería dar?

El derecho moderno admite, es verdad, para el caso de incumplimiento de una obligación emergente de contrato bilateral, que la contraparte elija entre la demanda de cumplimiento y la de disolución del contrato; pero en el derecho romano este régimen existe sólo para los contratos innominados. Y esto sólo se puede explicar refiriendo los dos tipos de protección a dos diversas fases históricas.

La multiplicidad de los nombres de la acción dirigida a obtener la contraprestación nos advierte que precisamente en esta parte (γ) debe buscarse el aporte posclásico justiniano. Para los clásicos, toda acción tiene un nombre, que corresponde a su co-

locación y formulación edictal; solamente después de la desaparición del procedimiento *per formulas*, es decir, en la época posclásica, se pudo tener tanta indiferencia por el nombre de la acción. Alguno de estos nombres es, en fin, contradictorio; ¿cómo se puede hablar de una *actio in factum civilis*, si en el sistema formulario la *a. in factum* es precisamente la antítesis de la *a. civilis*? (cfr. p. 146). Agréguese que todos los lugares de las fuentes donde se encuentra la expresión *actio praescriptis verbis* fueron, desde hace tiempo, considerados corrompidos por razones de forma y de sustancia, y que en general los textos en que se habla de una acción para obtener la contraprestación están plagados de errores gramaticales, de ilogismos, de construcciones repugnantes a la mentalidad clásica; que, en fin, sobre el contrato innominado guardan completo silencio las fuentes clásicas que nos han llegado directamente; y aparecerá fundada la tesis radical, sostenida por notables estudiosos recientes, para la que el principio según el cual la prestación cumplida en vista de una contraprestación crea la facultad de pretender esta última, es propio del derecho justiniano, mientras el derecho clásico concedía al que hubiera cumplido, la repetición de lo que había dado o el remedio penal de la *actio doli*. La máxima de CELSO en D. 12, 4, 16: *nulla hic alia obligatio est quam ob rem dati re non secuta*, enunciaba en forma definitiva el pensamiento de la jurisprudencia.

Nada prueba que la expresión *agere praescriptis verbis* tenga cierta asonancia con la terminología formularia, y en especial con el nombre de las *praescriptiones* (p. 151); que esta aproximación sea todavía más sensible en la frase de C. 2, 4, 6 § 1, "*utilis actio, quae praescriptis verbis rem gestam demonstrat*"; que en una nota de ESTEBAN, jurista contemporáneo de JUSTINIANO, se haga la tentativa de construir la fórmula *praescriptis verbis* (Basilicas, 11, 1, 7, esolio Μαθών). Una institución como ésta del contrato innominado no pudo derivar del arbitrio del legislador; antes bien, debió ser recogida por los compiladores justinianos como un fruto ya madurado en aquellas escuelas posclásicas, cuya secular labor preparó en tan buena parte la obra de la compilación. Adiestradas en el lenguaje de los clásicos, expertas en el procedimiento que éstos describían, era natural que las escuelas mismas forzaran las concepciones nuevas de modo de colocarlas dentro de los antiguos esquemas. ¿No acostumbramos, acaso, también nosotros a

traducir en el lenguaje jurídico romano instituciones que sabemos modernas, con los únicos fines de una más precisa determinación y de un más fácil aprendizaje?

Con ello no se niega que también en la concepción de la acción dirigida a la contraprestación haya asomos clásicos, y como el eco de alguna discusión entre los juristas. En particular:

α) A propósito de la permuta, los juristas del primer siglo del Imperio discutían si debiese o no concebírsela como compraventa: los sabinianos, que apoyaban la solución afirmativa, daban una acción para la contraprestación, mientras que los proculeyanos, que sostenían la negativa, daban sólo la *condictio* en repetición de lo que se había dado. Acumulando los dos medios, y extendiéndolos de la permuta a todas las materias análogas, se tiene la solución admitida por los justinianeos para todos los contratos innominados.

β) En la discusión de la cuestión referida, tuvo entre los más antiguos juristas, todavía impregnados de cultura filosófica, gran relieve la concepción aristotélica del *συνάλλαγμα*, fuente de "ultro citroque obligatio", donde una obligación está en función de la otra y desaparece si ésta no se cumple. Este asomo doctrinal, que en la época clásica no tuvo ulterior fortuna, fué en cambio recogido y llevado a sus consecuencias en el mundo posclásico.

γ) Parece que el Edicto tuviese una cláusula contemplando el *aestimatum*, es decir, la convención en virtud de la cual alguien da una cosa a un corredor (*circitor*) y éste se compromete a pagarla a un precio desde ya fijado si llega a venderla, o, en caso contrario, restituirla al tradente. Los textos (indudablemente interpolados, aunque no sabemos dentro de qué límites) dicen que se había discutido si la relación debiese considerarse como venta o locación de cosa, o locación de obras o mandato, y que el pretor había cortado el nudo otorgando una *actio in factum* dirigida a la ejecución de la convención; los compiladores han generalizado la solución²⁴.

²⁴ La tesis a que me adhiero, preparada por investigaciones especiales de GRADENWITZ, de PERNICE y de NABER, fué sentada por PEROZZI (por último *Ist.*, 2ª ed., ps. 352 y ss.) y por BESELER (*Contributi*, 2, ps. 256 y ss.; 4, p. 135); a su demostración está dedicada la obra de DE FRANCISCI, *Συνάλλαγμα: storia e dottrina dei c. d. contratti innominati*, 2 vols., Pavia, 1913-1916. Hoy se la puede considerar como *communis opinio* (cuya san-

§ 3. LOS CONTRATOS FORMALES Y SUS SUSTITUTIVOS PRETORIOS

Razones que inducen a reunirlos en un solo grupo. Exclusión del *nexum*.

Los contratos formales en particular: 1) la *dotis dictio*; 2) el *iusiurandum liberti*; 3) la *vadiatura*; 4) la *praediatura*; 5) la estipulación; 6) el contrato literal clásico (los singrafas y los quirografas del derecho helenístico y la degeneración de la estipulación en el derecho justiniano); 7) el *iudicium*. — Promesas abstractas del derecho pretorio; 8) la *pecunia constituta*; 9) los *recepta*.

Tratamos en este párrafo tanto de los casos en que, según la terminología gayana, *verbis obligatio fit* (III, 92), como de aquellos en los cuales *litteris obligatio fit* (III, 128), que aunque reunidos por las características de la solemnidad y de la formalidad, deberían sin embargo someterse, en una exposición limitada al derecho clásico, a la distinción neta que GAYO señala entre las varias formas; pero preferimos discurrir conjuntamente sobre ellos por la contaminación que entre los dos tipos se produce, como veremos, en la época posclásica.

También aquí completamos la enumeración gayana con los contratos que nos son conocidos por otro conducto.

No corresponde insistir sobre el *nexum*. Ya en varios lugares (ps. 90, 227 y 318) se ha hecho mención de él, observando que este nombre, originariamente sinónimo de *mancipium* o *mancipatio*, es usado más frecuentemente para indicar aquella autopignoración, quizá también la constitución en calidad de prenda de las personas en potestad a que el deudor se prestaba para dar una garantía al acreedor, y que parece fuese rescatable mediante la prestación de servicios. Toda ulterior determinación del concepto es controvertida. En todo caso, no se trata de un contrato ni siquiera en el sentido relativamente amplio con que los clásicos entienden la palabra, y esto porque no sirve para crear la obligación sino más bien para garantizar al acreedor. Y se trata también, y es lo más importante, de una institución extinguida en época an-

ción definitiva está en LENEL, Ed. perp., 3ª ed., ps. 300 y ss.). Puntos de vista más conservadores y menos felices son los de BETTI, "Bull. Ist. Dir. Rom.", 28, ps. 3 y ss.; MEYLAN, *Nature et origine de l'a. pr. verbis*, Lausanne 1919; de [JOERS-] KUNKEL, *Römisches Recht*, p. 244; y por último de VOCI, *La dottrina romana del contratto*, ps. 231 y ss.

terior a aquella de que tenemos conocimiento verdaderamente histórico; si bien es cierto que no fué abolido por la *lex Poetelia Papiria de nexis*, atribuída al año 326 a. C., también lo es que quedó bastante restringido en su aplicación y decayó después rápidamente²⁵.

*
* *
*

Son contratos verbales, y —no obstante las dudas que alguna laguna del manuscrito ha suscitado— están mencionados por GAYO como tales, la *dotis dictio* y la *promissio iurata* (o *iusiurandum*) *liberti*.

1. La *dotis dictio* es una declaración solemne hecha por la mujer que va a casarse, o por el ascendiente varón, o por el deudor de aquélla, y tendiente a constituir determinados bienes en dote, desaparecida en el derecho justiniano. Por los vestigios conservados de GAYO (III, 95a) y por los epítomes posteriores, sabemos que podían ser objeto de este contrato cosas muebles e inmuebles, corporales e incorpóreas; y que su solemnidad consistía en una fórmula pronunciada sólo por el constituyente de la dote, probablemente *doti tibi erit*, o *dotis nomine tibi dico*, con la mención de las cosas dotaes. No sabemos, en cambio, de qué protección jurídica gozaba este contrato; y ni siquiera sabemos si transmitía inmediatamente la propiedad y los otros derechos, fundando únicamente una obligación de garantía, o si, como respondería mejor a las palabras gayanas, generaba solamente obligaciones²⁶.

2. La *promissio iurata liberti* es un juramento con el cual el esclavo manumitido se obliga a prestar ciertos servicios al patrono que lo ha liberado. La fórmula del juramento se usa con el fin de tender un puente entre los compromisos tomados por el sirvo antes de la manumisión y su confirmación después de haber alcanzado la libertad. Importaba, en efecto, al patrón que estaba por manumitir un esclavo, vincularlo hacia sí a determinadas prestaciones; pero privado como estaba de capacidad jurídica, el es-

²⁵ Cfr., por último, sobre el tema: LUZZATTO, *Per una ipotesi*, etc., cit., ps. 217 y ss.; MONIER, *Man. élém.*, 2ª ed., II, ps. 13 y ss.; KOSCHAKER, "Rev. Fundac. Savigny", 63, 1943, ps. 457 y ss.

²⁶ El problema no está resuelto ni siquiera por el papiro vuelto a publicar en el nº 20 de *mis Negotia*, sobre el cual v. ahora BERGER, *Jo. of jurist. papyrol.*, 1, 1945, ps. 13 y ss.

clavo no habría podido hacerle una promesa válida. Se recurrió por eso a la religión (*fas*), frente a la cual también el esclavo es capaz de contraer un compromiso; y se estableció que inmediatamente antes del acto de manumisión el esclavo vinculase su conciencia prestando un juramento al patrón. Éste era repetido inmediatamente después de la manumisión, y esta vez con efecto de obligación civil.

La institución es probablemente tan antigua como la manumisión; y es muy probable que ya en la época de las *legis actiones* el amo tuviese modo de obrar (quizá *per conductionem*, cfr. p. 135) contra el liberto que dejara de cumplir. Pero de tal institución los manumitentes se valieron fuera de toda medida, empeñando a sus libertos a prestaciones gravosas, como el pago periódico de dinero. En este punto intervino el pretor, quien, conservando la acción civil por lo que se refería a los servicios periódicos (días de trabajo) a que los libertos se obligaban, negó la sanción a las promesas que resultaran excesivamente onerosas (*onerandae libertatis causa imposita*)²⁷.

*
* *

Una posición preeminente en el sistema de los contratos formales (y precisamente entre los verbales) tienen los contratos de garantía. Su característica común es la de estar destinados, según la concepción originaria, a prometer el hecho de un tercero, con el efecto de que el comportamiento de éste representa no ya el objeto de una *obligatio* existente por sí, sino una causa de liberación del garante que es el único *obligatus*. El más antiguo entre los contratos en cuestión es probablemente:

3. La *adiutura*. Del *vas* sabemos de cierto que era un garante del hecho ajeno; por la analogía con el *praes* (se considera *praes* = *prae-vas*), es bastante probable que la garantía se asumiese respondiendo *vas sum* al acreedor que preguntaba: *¿vas es?* La única aplicación segura de la institución está en el proceso, con el fin de garantizar la comparecencia del demandado en juicio; tanto

²⁷ La relación entre los medios concedidos por el *ius civile* y la intervención pretoria es muy controvertida. Repitiendo cuanto he sostenido otra vez (*Le genti e la città*, 1913, ps. 65 y ss.), estoy satisfecho de estar de acuerdo con H. KRUEGER, "Rev. Fundac. Savigny", 37, 1916, ps. 280 y ss.

es así que todavía en la época clásica se llama *vadimonium* a la promesa de comparecer, aunque se preste ahora por estipulación del mismo demandado, con intervención de garantes (*sponsores*). Algo más conocida es:

4. La *praediatura*. También los *praedes* son garantes e intervienen en el procedimiento de la *legis actio sacramenti* —en garantía del cumplimiento de la apuesta (*praedes sacramenti*) y en garantía de la restitución de la cosa y de los frutos por parte del poseedor interino (*praedes litis et vindictiarum*); cfr. p. 130—, sea en las adjudicaciones de tributos y de trabajos públicos. El contrato conserva bien delineada también en la época histórica la estructura primitiva; el adjudicatario, el *manceps*, no está como tal *obligatus* hacia el Estado, sino que la obligación pesa sobre él solamente cuando se haya hecho *praes* de sí mismo. El gramático Festo, en la obra *De verborum significatione*, dice precisamente hablando del *manceps*: “*qui «idem praes» dicitur, quia tam debet praestare populo quod promisit quam is qui pro eo praes factus est*”²⁸.

Faltando el *manceps* (o el litigante) a la promesa, el procedimiento ejecutivo se dirigía no contra él sino contra el *praedes*. Del procedimiento no tenemos conocimiento seguro; se sabe que las reglas eran algo diversas según que los garantes hubiesen gravado fundos (*subsignatio praediorum*) o se hubiesen empeñado personalmente, y se sabe también que en ambas hipótesis el procedimiento tenía dos fases, respectivamente designadas con los nombres de *venditio ex lege praedictoria* y *venditio in vacuum*; pero las tentativas de mayor precisión no fueron alcanzadas²⁹.

²⁸ Todavía hoy me parece que ninguna frase podría expresar mejor la profunda diferencia que hay entre la concepción primitiva de la garantía y su función en el derecho evolucionado; para que el adjudicatario mismo esté sujeto a la acción ejecutiva del acreedor, es necesario que sea considerado como un garante. Sin embargo, debo advertir que la doctrina aquí sostenida sobre las obligaciones de garantía originarias es muy combatida; últimamente, con la acostumbrada elegancia de argumentación, por DE MARTINO, “*Stud. e Docum.*”, 6, 1940, ps. 132 y ss.

²⁹ La hipótesis adelantada por PARTSCH, *Demotische Urkunden zum ägyptischen Bürgschaftsrecht* [Documentos demóticos sobre el derecho egipcio de garantía personal] (“*Memorie Accad. Sassone*”, 32, 1920, ps. 650 y ss.), ha caído con la nueva lectura que del documento principal ha dado GUÉRAUD en la edición de las *Ἐντεῦξις* (*Public. de la Soc. Royale de Pa-pyrologie du Caire*, 1, 1932), nº 61.

Mucho mayor relieve tiene

5. La *estipulación*, o *verborum obligatio* en sentido estricto³⁰, eje del sistema contractual romano. Y no solamente como capaz de realizar, en el campo de las obligaciones, cualquier intento práctico³¹, sino también como medio preferido para actuar o reforzar la tutela jurídica de las relaciones más variadas; cfr., por ejemplo, en la p. 161 sobre las *stipulationes praetoriae*, y en la p. 159 sobre la marcha del proceso interdictal. Precisamente por su indefinida variedad de aplicaciones, la estipulación ha sido el paradigma en torno al cual se ha desarrollado la doctrina clásica de la *obligatio*.

La estipulación consiste en una interrogación solemne, dirigida por el futuro acreedor al futuro deudor, y en una inmediata y congruente respuesta de éste; entendida la congruencia en el sentido de que el deudor debe asumir la obligación con el mismo verbo usado por el acreedor, y no puede agregar ulteriores determinaciones a lo que el acreedor ha precisado en su pregunta. En su tipo originario, que tiene el nombre especial de *sponsio*, la solemnidad está toda en el uso de las formas verbales ¿*spondes?*, *spondeo*; más tarde se admiten, con igual eficacia, las formas ¿*promittis?*, *promitto*; ¿*fideiubes?*, *fideiubeo*; ¿*dabis?*, *dabo*; ¿*facies?*, *faciam*, etc.; pero, cuando la difusión de las relaciones comerciales entre Roma y los otros países del Mediterráneo condujo a la creación de instituciones aplicables en todo el mundo civilizado (*ius gentium*), se extendió entre los peregrinos el uso de la estipulación; solamente la veneración por el tipo más antiguo hizo que la forma *spondes? spondeo*, permaneciese *iuris civilis*, es decir, reservada a los ciudadanos romanos. Desde este período se pudo estipular también en griego con las palabras ὁμολογεῖς; ὁμολογῶ, δώσεις; δώσω, ποιήσεις; ποιήσω; etc.

En las formas de la estipulación puede alojarse todo contenido; de aquí la distinción entre estipulación *in dando* (que tiene por objeto la transmisión de la propiedad o la constitución de derechos

³⁰ En rigor, como el verbo *stipulari* se refiere sólo a la declaración de voluntad del acreedor, lo mismo se debería decir del sustantivo *stipulatio*. Sin embargo, también en la época clásica se lo usa muchas veces para indicar el negocio entero.

³¹ En este sentido se ha dicho, en la p. 352, n. 23, que la estipulación se presenta al pensamiento moderno más bien como una forma contractual que como un contrato. Pero la estructura unilateral y el rígido encuadramiento verbal trasforman, como veremos, toda convención sujeta a la forma de la estipulación, en negocio formal y abstracto.

reales) e *in faciendo* (que tiene por objeto cualquier otro comportamiento)³². Por ejemplo, son *in dando* las estipulaciones *centum dari*, *fundum in agro Capenate qui Gargilianus vocatur dari*, *usum fructum dari*; *in faciendo*, las estipulaciones *servum tuum Stichum manumitti*, *insulam fieri*, *neque per te neque per heredem tuum fieri quominus mihi ire agere liceat*.

Es opinión ampliamente aceptada³³ que el origen de este contrato haya estado en la asunción de garantía por el hecho de un tercero; argumentos específicos en su favor son, por una parte, el hecho de que el sustantivo *sponsor*, forma nominal de *spondeo*, conserva también en la época clásica el único significado de garante, y por la otra, la forma pasiva que tiene el verbo que indica el comportamiento a observar (ejemplo: "*spondes dari*", no ya *dare*, "*centum?*"), forma idónea para indicar, más bien que la actividad de la misma persona que *spondet* o *promittit* o, análogamente, el hecho de un tercero. Por otra parte, la hipótesis que reconoce el origen de las obligaciones en las asunciones de garantía responde a una forma general del pensamiento primitivo (cfr. p. 318) que investigaciones recientes han puesto en claro, tanto para el antiguo derecho germánico como para el griego, para el egipcio y el babilónico.

Permanece algo en la sombra el modo con el cual se ha pasado de la concepción primitiva de la *sponsio* a la que domina in-contrastada en el derecho clásico, es decir, la promesa normalmente dirigida al hecho propio, y que sólo en casos especiales y con particulares recursos técnicos asume función de garantía, accesoria

³² También negativo; de la estipulación *in non faciendo* los romanos no hacen una categoría aparte.

³³ Fué expuesta por MIRREIS en el estudio citado en la p. 315, n. 1; cfr. también *Römisches Privatrecht*, I, ps. 266 y ss. La aceptan entre nosotros MARCHI y BETTI cits., mientras no parece lograda la mediación que entre esta doctrina y la precedente *communis opinio* ensaya PEROZZI, *Dalle obblig. da contratto*, etc., en "*Memorie Accad. Bologna*", sec. jur., 10, 1916, ps. 43 y ss. Hoy alguno piensa que GAYO (IV, 17 a), diciendo aplicable sobre la base de las XII Tablas la *legis actio per iudicis postulationem* a los créditos procedentes de estipulación y dando como ejemplo una estipulación de dinero del todo análoga a la clásica, deponga contra la tesis de MIRREIS; pero en realidad el nudo de esta tesis, que no debe confundirse con la particular referencia que MIRREIS mismo hacía a las garantías procesales, alude a una época en mucho anterior a las XII Tablas, y no es, en consecuencia, tocado por el nuevo texto (así en particular MEYLAN, *Acceptilation et paiement*, Lausanne, 1934, ps. 5 y ss.; ARANCIO-RUIZ, "*Bull. Ist. Dir. Rom.*", 42, 1935, ps. 609 y ss.).

de la obligación principal ajena; pero también aquí corresponde suponer el pasaje a través de un estadio intermedio, en el cual el deudor haya asumido, como en la *praediatura*, la garantía del hecho propio³⁴.

Volviendo a la estipulación clásica, cuyas formas hemos descrito sobre el modelo de GAYO, es controvertido si también los juristas posteriores mantuvieron firme el principio de la congruencia entre pregunta y respuesta. Si se prestase fe a las decisiones atribuidas a ULPIANO en D. 45, 1, 1, §§ 2 y 6, se debería pensar que en la época de los Severos se consideraba suficiente, como respuesta al *dabis?* del acreedor, un simple *quidni?* (¿"por qué no?"), y que se diese la respuesta en distinto idioma; pero es más que probable la interpolación de estos pasajes, afirmada entre otros por RICCOBONO. Igualmente ha de considerarse, a pesar de los testimonios en contrario del § 1 del mismo fragmento y del fr. 137 pr. h. t., que el derecho clásico haya mantenido firme el requisito de la inmediatez de la respuesta (*unitas actus*).

No menos tenaz, según parece, fué la persistencia de los clásicos en deducir las consecuencias de la estructura de la estipulación como negocio fomal. Por derecho civil, la expresión gayana "*verbis contrahitur obligatio*" debe entenderse en sentido absoluto; la obligación nace de la pronunciación de determinadas palabras, y no se puede, en consecuencia, hacer lugar a investigación alguna respecto de la causa. Como de costumbre, el principio del derecho civil no pudo ser dejado de lado por el pretor, pero reco-

³⁴ Otra institución bastante afin, en la cual el pasaje se puede observar más fácilmente, es la del *vindex*, quien, como sabemos (p. 129), puede intervenir para liberar al deudor de la *manus iniectio*, ofreciéndose a demostrar su falta de fundamento y exponiéndose él mismo, en caso de sucumbir, a la acción ejecutiva; en compensación, tiene el derecho de reembolsarse contra el deudor por el cual ha intervenido. Esta relación es, en el pensamiento de los antiguos, tan semejante a la *sponsio*, que la misma acción (la *a. depensi*) tanto se da al *sponsor* como al *vindex*, para recuperar en el doble contra el deudor cuanto hayan pagado al acreedor. Pero en los casos más recientes de créditos tutelados por *manus iniectio*, las leyes permitieron al deudor rechazar por sí la mano del acreedor e iniciar un proceso de verificación (*manum sibi depellere et pro se lege agere*); he aquí cómo al garante extraño se sustituía el deudor como garante de sí mismo. Cfr. sobre este desarrollo, MARCHI, op. cit.; KOSCHAKER, "Rev. Fundac. Savigny", 37, 1916, ps. 348 y ss.

De la acumulación de la deuda y la garantía en la misma persona debía necesariamente derivar, en un pueblo de tan profundo sentido jurídico como el romano, la identificación absoluta, y sin residuos, del *debitum* con la *obligatio*: cfr. p. 319.

nociendo las iniquidades que en algunos casos derivaban de él, éste debió, aquí como en otros supuestos, salvar el obstáculo. A tal fin sirvieron los remedios contra el dolo (cfr. ps. 116 y ss.); por ejemplo, si alguien a quien yo había solicitado dinero en préstamo se ha hecho prometer la suma mediante estipulación y después no me la ha dado, puedo oponer victoriosamente a su *actio ex stipulatu* la *exceptio doli*. Otras veces se recurrió al remedio de reconocer en las declaraciones hechas por las partes antes o después de la estipulación el contenido de un *pactum* (cfr. § 5); lo que permitía conceder al deudor demandado una *exceptio pacti*.

Todo intento de las partes puede ser traducido en estipulación, incluso si prescindiendo de aquella forma diera lugar a otro contrato o si este otro contrato está ya perfeccionado en virtud del acuerdo producido entre las partes o de la ya verificada dación de la cosa; por ejemplo, comprador y vendedor pueden, después de haberse puesto de acuerdo sobre la cosa y el precio, prometerse recíprocamente, en forma solemne, una y otra prestación; y el depositario puede prometer la restitución de la cosa, el mutuario la restitución del *tantumdem*. En estos casos no subsistía en el derecho romano ni la venta, ni el depósito, ni el mutuo, sino solamente la estipulación, cuya solemnidad cumplida extinguía la obligación causada si había nacido ya. La jurisprudencia republicana preparó cuidadosamente los formularios mediante los cuales la estipulación era idónea para las diversas contingencias; y favoreció también el hábito de redactar un documento escrito para recuerdo de la estipulación verificada. Pero entre los clásicos el documento no tuvo nunca otro valor que el de prueba; y la prueba podía también quedar desvirtuada si se demostraba que no se habían pronunciado las palabras solemnes.

La acción en tutela de la estipulación varía según su objeto. Antes que la distinción entre estipulaciones *in dando* e *in faciendo*, es aquí decisiva la distinción entre *stipulationes certi* e *incerti*. Se estipula un *certum* cuando es objeto del contrato una suma o cantidad de cosas fungibles o bien una cosa individualmente determinada; se estipula un *incertum* cuando el objeto no está determinado en su individualidad ni pertenece al número de las cosas fungibles (estipulaciones alternativas y genéricas, cfr. cap. XIX, § 2), o cuando la estipulación es *in faciendo*.

Por lo menos para las *stipulationes certi*, la ley de las XII Tablas disponía que se obrase con la *legis actio per iudicis pos-*

tulationem, acción que tenía la ventaja de no imponer ninguna pena al perdedor; parece, sin embargo, que ya antes se pudiese intentar la *legis actio sacramenti in personam*, y que las XII Tablas hayan dejado al actor la elección entre los dos tipos de proceso. Más tarde, el surgir de la *condictio, legis actio* destinada a la repetición de toda *certa pecunia* o *certa res*, puso a disposición de las partes todavía un tercer medio, que probablemente determinó un rápido abandono del procedimiento sacramental. La superstite concurrencia entre la *legis actio per iudicis postulationem* y la *per conductionem* puede darnos razón del hecho de que para la sucesiva época formularia, mientras algún raro texto declara aplicable la *actio certae creditae pecuniae* y la *condictio certae rei*, la mayor parte de los pasajes de los juristas habla de una *actio ex stipulatu certi*; cabe pensar, en efecto, que el pretor, traduciendo las antiguas *legis actiones* en términos formularios, haya preparado, al lado de las fórmulas sin indicación de fuentes que correspondían a la antigua *condictio* (p. 140, 1er. ejemplo, y 340), también otras en las que se agregaban las palabras *ex stipulatu*, y que éstas hayan sido preferidas en la práctica. Sin duda se llamaba *actio ex stipulatu incerti* a la que se daba para las estipulaciones de objeto indeterminado o *in faciendo*, y cuya fórmula era construída como las nacidas de los contratos consensuales (p. 140, 4º ejemplo), salvo la omisión de las palabras *ex fide bona*.

6. El contrato literal clásico, llamado *expensi latio* o *nomen transscripticium*, no parece que haya sido una forma muy difundida; salvo alguna referencia ciceroniana, nuestros conocimientos sobre el particular se reducen a lo poquísimos que dice GAYO (III, 128 y ss.).

En la época republicana avanzada, se había impuesto entre los padres de familia el uso de llevar libros de las entradas y las salidas (*codices accepti et expensi*), y de anotar en ellos también los créditos y las deudas de dinero; y las anotaciones hechas en formas preestablecidas en los libros del acreedor podían crear obligaciones. Precisamente GAYO distingue dos especies de anotaciones, *nomina arcaria* y *nomina transscripticia*; las primeras tienen valor de simple recuerdo de una obligación preexistente, que dejan inalterada; las segundas, en cambio, trasforman la obligación preexistente en una nueva. Esto puede ocurrir, continúa, mediante *transscriptio a re in personam* o mediante *transscriptio a persona in personam*: la primera especie de *transscriptio* persigue el fin

de obligar *litteris* a la misma persona que estaba ya obligada por otra causa, por ejemplo compraventa o locación; la segunda sustituye un acreedor o un deudor por otro.

Sabiendo esto, sabemos en verdad demasiado poco; y en particular no vemos cómo resultase en la práctica la diferencia entre el *nomen arcarium* y la *transscriptio a re in personam*. Evidentemente, la fórmula usada en la anotación debe haber tenido estructura diversa en uno y otro caso; y quizá todas las veces que las partes buscaban el efecto de la *transscriptio* (fuese *a se in personam* o *a persona in personam*) intervenía o de cualquier otra manera consentía el (nuevo) deudor³⁵.

De cualquier modo, el *nomen transscripticium* que no fué recogido por el derecho justiniano, debía ser ya en la época clásica un residuo histórico. Residuo de una costumbre propia de los últimos siglos de la República, pero bien pronto superada por el predominio de la institución más típicamente nacional: la *obligatio verbis*.

*
* *

Después de haber descrito el *nomen transscripticium*, GAYO (III, 134) prosigue: "*Praeterea litterarum obligatio fieri videtur chirographis et syngraphis, id est si quis debere se aut daturum se scribat: ita scilicet, si eo nomine stipulatio non fiat: quod genus obligationis proprium peregrinorum est*".

En el comentario de GAYO, estas palabras no tienen otro valor que el de curiosidad erudita: en su sistema, que es de derecho ro-

³⁵ Una hipótesis aguda hay en SIBER, *Römisches Privatrecht*, ps. 180 y ss.; donde, sin embargo, los textos de GAYO, como así también los de TEÓFILO (*ad Inst.*, 3, 21 pr.) y de CICERÓN (*pro Rosc. com.*), están sometidos a una prueba demasiado dura. El problema parece insoluble en el estado actual de nuestros conocimientos. La arenga ciceroniana *pro Roscio comoedo* ha dado mucho que hacer a los intérpretes por las dificultades planteadas respecto de la prueba, y ha alimentado, en consecuencia, la opinión de que para la validez de la obligación fuese necesaria una especial escritura también en los libros del deudor; pero ahora algunas tablillas enceradas procedentes de las excavaciones de Herculano parecen imponer la conclusión de que los romanos separaran netamente la forma creadora de la obligación (anotación solemne en los libros del acreedor) de la relativa prueba (dada mediante *testatio* o mediante documento autógrafo librado por el deudor).

mano puro, συγγράφαί y χειρόγραφα no habrían debido encontrar lugar, y el haberlos nombrado figura entre los indicios de la pertenencia de nuestro jurista al mundo provincial.

Ya sabemos (cfr. ps. 227 y ss.) cómo, por la importancia dada a las formas escritas con relación a las orales, el mundo helenístico representa una concepción antitética de la romana. Por lo que se refiere a las relaciones de deuda y de crédito, la difusión del documento no ofrece por sí una prueba tan decisiva como en materia de transferencia de la propiedad; documentos contractuales se redactaban, en efecto, también en Roma, para atestiguar el perfeccionamiento de toda especie de contratos, y sobre todo de las estipulaciones. Sin embargo, mientras el documento romano es exclusivamente probatorio, las palabras de GAYO llevan a admitir que las provincias helenísticas conocieron aquel tipo de documento a que hoy se da el nombre de *dispositivo*: documento que se considera causa y fuente de la obligación, independientemente de haberse producido efectivamente entre las partes aquellas circunstancias de hecho y declaraciones de voluntad que el documento testimoniaría. Que GAYO pensó en documentos semejantes, debería inducirse sin más del hecho de que habla de ellos como de *litterarum obligationes*, después de haber expresado netamente, mediante la contraposición entre los *nomina arcaria* y los *nomina transcripticia*, el concepto rígidamente técnico que tiene de tal *obligatio*; pero mejor todavía lo demuestran las palabras "ita scilicet, si eo nomine stipulatio non fiat". Con estas palabras quiere decir que, si el documento hace fe de una estipulación verificada, su valor sólo puede ser probatorio respecto de la estipulación, única fuente de la obligación; en cambio, si no ha tenido lugar una estipulación, causa de la obligación es el mismo documento.

De lo que destacamos del pasaje de GAYO tenemos la prueba en los papiros greco-egipcios. Resulta de éstos que, al lado de los documentos probatorios, había muchos dispositivos, es decir, destinados a producir efectos jurídicos independientemente de la correspondencia de sus atestaciones con las contingencias reales. Sobre todo fué usado ampliamente con esta función del δάειον, conteniendo la declaración de haberse verificado la entrega de una suma a título de mutuo, pero en circunstancias que muchas veces demuestran que la entrega no había existido. Por lo demás, en ellos figura a menudo una cláusula destinada a afirmar el valor obligatorio del documento como tal: ἡ συγγραφή κυρία ἔστω, con va-

rios agregados, especialmente el de las palabras παντὶ τῷ ἐπιφέροντι ("para cualquiera que lo presente"), de las cuales muchos han deducido que semejantes documentos funcionaban como títulos al portador³⁶.

Después de la extensión de la ciudadanía (año 212), la práctica provincial se esforzó también aquí, como en el caso de la tradición (ps. 227 y ss.), por conciliar el respeto aparente al derecho de los dominadores con la sustancial conservación del derecho local. Parecería, a primera vista, que en esta materia el derecho romano hubiese ofrecido mayor resistencia: el viejo δάνειον dispositivo desaparece del todo, y en cambio se hace cada vez más frecuente, en la documentación de las relaciones de deuda y de crédito, la cláusula estipulatoria καὶ ἐπερωτηθεὶς ὁμολόγησα (*et stipulatus spopondi*), calcada sobre aquellos documentos puramente romanos en los cuales, como se ha dicho, se conservaba el recuerdo de los pactos concluidos entre las partes y de la estipulación con la cual se había contraído el vínculo obligatorio³⁷. Pero, mirando bien, la recepción del contrato verbal romano es del todo aparente; en efecto, aquella cláusula estipulatoria no aparece solamente en documentos de deuda y de crédito, sino también en negocios jurídicos unilaterales como el testamento. Ahora bien; si en negocios semejantes, donde no se podría siquiera imaginar quién pudiese formular al disponente la pregunta esencial de la estipula-

³⁶ Me refiero rápidamente a cuestiones que son objeto de viva discusión. La doctrina del contrato literal griego, es de MITTEIS, *Dir. dell'impero e dir. popolare*, ps. 459 y ss.: entre los más recientes cfr. FREUNDT, *Wertpapiere im antiken und frühmittelalterlichen Rechte* [Títulos de crédito en el derecho de la antigüedad y de la alta Edad media], Leipzig, 1910; PARTSCH, en la "Zeitschrift für das gesamte Handels und Konkursrecht" ["Revista de Derecho Comercial y Concursal"], 70, 1912, ps. 437 y ss.; A. SEGGRÉ, "Bull. Ist. Dir. Rom.", 34, 1925, ps. 75 y ss.; y, en sentido opuesto, BRANDILEONE, *Sulla supposta obb. litt. nell'antico dir. greco*, en "Rend. Accad. Scienze Bologna", sec. jur., 1920. Por último, cfr. ARANGIO-RUIZ, en nota al n° 25 de los *Papiri della R. Università di Milano* (1937). Sobre la degeneración de la *stipulatio* romana, cfr., además de los escritos citados, también BENDER, *Il contratto letterale giustiniano*, en *Studi in onore di B. Brugi*, 1910, ps. 339 y ss.; FERRARI, *La degenerazione della stipulatio nel dir. intermedio*, en "Atti Ist. Veneto", 69, 1910, 2, ps. 743 y ss. (notable especialmente por los documentos occidentales de la alta Edad media); y principalmente RICCIBONO, "*Stipulatio*" ed "*instrumentum*" nel diritto giustiniano, en "Rev. Fundac. Savigny", 35, 1914, ps. 214 y ss.; 43, 1922, ps. 262 y ss.

³⁷ Cfr. todavía una vez la tablilla de Transilvania transcrita en la p. 341, nota 9.

ción, los notarios greco-egipcios no han tenido dificultad en insertar aquella cláusula, quiere decir que su inserción en los documentos no correspondía a un efectivo cumplimiento de las formalidades verbales. De donde se planteaba a la legislación el problema de si los efectos obligatorios de la estipulación debiesen hacerse derivar todavía de la pronunciación de las palabras solemnes, o más bien de la cláusula correspondiente del documento.

En las constituciones imperiales del siglo III y de los primeros años del IV, la respuesta es conforme a los principios del derecho clásico, es decir, que el documento ofrece sólo una prueba de la estipulación concluida, prueba que cae cuando por otra vía se demuestre no haber sido pronunciadas las palabras solemnes. Pero en textos posteriores, provenientes de los emperadores de los siglos IV y V o manipulados en ese tiempo, vemos afirmada la bien diversa regla según la cual la declaración del documento equivale a la estipulación efectivamente cumplida. Cfr., p. ej., *Inst.*, 3, 19, 17: "Si scriptum fuerit in instrumento promississe aliquem, perinde habetur atque si interrogatione praecedente responsum sit"; D. 45, 1, 30 (interpol.): "Sciendum et generaliter quod, si quis se scripserit fideiussisse, videri omnia sollemniter acta". Una constitución de LEÓN (C. 8, 37, 10, año 472) admite que las estipulaciones tengan valor también si no están formuladas con palabras solemnes y en forma de pregunta y respuesta, sino "quibuscumque verbis pro consensu contrahentium compositae sint", donde el verbo *componere* alude a la forma que el notario daba a las declaraciones de las partes. Y una constitución de JUSTINIANO mismo (I. 14, h. t.) dispone que la declaración documental en la que se expresa que ha tenido lugar determinada estipulación, hace plena fe mientras no se demuestre que en la fecha de redacción del documento uno de los contratantes estaba ausente de la ciudad en la cual resultaría cumplido el negocio; el emperador declara expresamente que esto sucede no para facilitar la prueba, sino con el fin de evitar la comparecencia de las partes ante el notario, máxime cuando, por la posición social o por el sexo, tal comparecencia puede ser inconveniente.

No hay quien no vea que de este modo la estipulación quedaba completamente desnaturalizada; si, no obstante ello, continuó siendo practicada en las viejas formas en aquellas partes del Occidente en que mejor se habían aclimatado, esto nada prueba respecto del Imperio de Oriente, único territorio en el cual el derecho justinia-